

บทที่ 5

การพิจารณาคดี การระงับข้อพิพาทและที่ปรึกษากฎหมาย

การใช้กฎหมายอิสลามนอกจากจะได้กำหนดถึงเนื้อหาของหลักกฎหมายอิสลามและวิธีการใช้กฎหมายอิสลามที่จำเป็นเอาไว้ ยังต้องกำหนดถึงวิธีพิจารณาคดีที่เป็นข้อพิพาทของมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกด้วย

เนื่องจากกฎหมายอิสลามมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมายแพ่ง คือ เป็นกฎหมายคำสอน การใช้กฎหมายอิสลามจึงมีความสัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ ทางคำสอนอิสลาม เพราะชุมชนมุสลิมไม่มีการแบ่งแยกกันระหว่างสถาบันทางคำสอนกับสถาบันทางฝ่ายบ้านเมือง สถาบันทางคำสอนจึงเข้ามาดำเนินการต่าง ๆ แทนสถาบันทางฝ่ายบ้านเมืองในบางกรณีโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมรดก ดังนั้น สถาบันทางคำสอนจึงมีความจำเป็นสำหรับการใช้กฎหมายอิสลาม เพราะเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติศาสนกิจของอิสลามคำสอนให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของคำสอน สถาบันทางคำสอนจึงกลายมาเป็นผู้บริหารกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมรดก เพราะกฎหมายอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมคำสอนของคำสอน เมื่อรัฐได้ยอมรับหลักกฎหมายอิสลามเป็นระบบกฎหมายหนึ่งของประเทศ รัฐจึงต้องยอมรับสถาบันทางคำสอนอิสลามด้วย โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายอิสลามเอาไว้

สถาบันทางคำสอนอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีและการระงับข้อพิพาทตลอดจนให้คำปรึกษาตามกฎหมายอิสลาม คือ

1. ศาลคำสอน (Shariah court)
2. คณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม
3. สำนักงานทะเบียนสมรส หย่าและอื่น ๆ

สถาบันต่าง ๆ นี้ มีอำนาจหน้าที่ของแต่ละสถาบันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โดย ผู้จัดทำไป

ดาวน์โหลดเมื่อ 21/08/2569 14:35:16



ศาลศาสนา (Shariah court)¹

ศาลที่ทำการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เรียกว่า ศาลชาเรีย หรือ ชารีอะห์ ศาลศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการใช้กฎหมายอิสลามในฐานะที่เป็นสถาบันในการบริหารกฎหมายอิสลาม กฎหมายอิสลามก็เหมือนกับกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้มีสถาบันที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในการบริหารกฎหมายอิสลามเช่นเดียวกับศาลพิเศษอื่น ๆ เช่น ศาลภาษี ศาลปกครอง เหล่านี้เป็นต้น

ในสมัยก่อนศาสนาอิสลามมีลักษณะเป็นศาลแบบ Tribunal คือ เป็นศาลในความหมายกว้าง ๆ ทำการพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม โดยผู้นำทางศาสนาในแต่ละท้องถิ่นทำการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงาน การหย่า การปกครองผู้เยาว์ การลงโทษโดยการขับออกจากชุมชน² ศาลศาสนาอิสลามในสมัยนั้นอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ในอินโดนีเซียในบางแห่งที่มีการปกครองโดยสุลต่านก็มีศาล Sultanate court ทำการพิจารณาคดี³ ในฟิลิปปินส์ก็เรียกว่า Agama court ในศรีลังกาเรียกว่า Quazi Court ส่วนในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการก่อตั้งศาลพิเศษขึ้นเพื่อทำการพิจารณาคดีตามกฎหมายและประเพณีของชนชาติ โดยก่อตั้งศาลกรมท่าซ้าย เพื่อทำการพิจารณาคดีชนชาติจีน ศาลกรมท่าขวาทำการพิจารณาคดีของชนชาวมุสลิม โดยศาลทั้งสองทำการตัดสินคดีตามกฎหมาย

¹คำว่า Sharia ตามนัย แปลว่า ถนนอันไปสู่สถานที่อันมีน้ำ หรือทางซึ่งพึงเจริญรอยตาม คำพ้องนี้หมายความว่า กฎหมายทางศาสนาอิสลามทั้งปวง ซึ่งอาจมีลักษณะบางประการไม่เป็นกฎหมายตามที่เข้าใจกันในสมัยนี้ก็ได้ (วันชัย แยมกลั่น) กฎหมายอิสลาม, บทประพันธ์เล่มที่ 20 ตอน 4 ตุลาคม 2505)

²Bustanul Arifin, The Administration of Shari'ah laws in Indonesia,^{1st} Asean Shari'ah Administrators conference workshop, August 7-11 1983, Manila Philippines, p. 12.

³พิพัฒน์ สักการกิจ, กฎหมายอิสลาม, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 316.

และประเพณีของชนชาตินั้น ๆ แต่สำหรับชนชาติจีนไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือประเพณีผิวเผินมรดกเป็นการแน่นอน ศาลกรมทำข้ายจึงใช้กฎหมายไทยบังคับ ส่วนชนชาติอิสลามซึ่งมีกฎหมายและประเพณีแน่นอนในเรื่องผิวเผินมรดกศาลกรมทำข้ายจึงใช้กฎหมายอิสลามบังคับ¹

ศาลศาสนาอิสลามเริ่มได้รับการกระทบกระเทือนจากการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคม โดยเจ้าอาณานิคมได้นำเอาระบบกฎหมายของตนมาใช้กับอาณานิคมของตน ซึ่งโดยปกติแล้วก็เป็นกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ในขณะที่เดียวกันเจ้าอาณานิคมก็ได้ก่อตั้งศาลแพ่ง ศาลอาญา เพื่อทำการพิจารณาพิพากษาคดี การพิจารณาคดีทั้งหมดต้องกระทำโดยศาลแพ่งหรือศาลอาญาเท่านั้น

ในระยะแรกเจ้าอาณานิคมได้พยายามทำลายล้างขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวพื้นเมือง ทำให้ศาลศาสนาอิสลามที่ทำการพิจารณาคดีของชุมชนมุสลิมไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้าอาณานิคม ต่อมาเจ้าอาณานิคมไม่อาจจะทนต่อสภาพความต้องการของประชาชนมุสลิมก่อรูปกับเพื่อความต้องการความสับสนุ่นจากผู้นำศาลศาสนาอิสลาม เจ้าอาณานิคมจึงได้ยอมรับให้นำเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ได้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของประเทศ แต่การใช้กฎหมายอิสลามก็กระทำโดยศาลแพ่ง ลักษณะภาพของกฎหมายอิสลามในสมัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผิดปกติ เช่นกรณีของประเทศศรีลังกา ซึ่งกฎหมายอิสลามได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายในประเทศสำหรับบังคับใช้กับมุสลิม แต่ในขณะนั้นกลับไม่มีศาลศาสนาอิสลามเพื่อทำการบริหารกฎหมายอิสลาม แต่มีศาลแพ่งที่มีผู้พิพากษาเป็นชาวอังกฤษและไม่ใช่มุสลิมซึ่งแทบจะไม่รู้หลักกฎหมายอิสลามเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลาม² และในกรณีของอินเดียนั้นก็เช่นเดียวกัน ผู้พิพากษาของอังกฤษเป็นผู้ทำหน้าที่แทน Qadis ในศาลแพ่ง³

¹พิพนธ์ สักราญกูร, กฎหมายอิสลาม, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 316.

²Ahmed Hilmy Mohideen, Physical organization of Shari'ah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shari'ah Administrators Conference Workshop, August 7-11 1983, Manila Philippines, p. 2.

³Ahmad Ibrahim, Islamic Law in Malaya, Malaysian Sociological Institute, (Kulalumpur : Polygraphic Press Sendirian Berhad, 1975), P. 112.

และต่อมาเจ้าอาณานิคมจะได้รับยอมรับศาลศาสนาอิสลาม เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารกฎหมายอิสลาม แต่ได้มีการจำกัดเขตอำนาจศาลศาสนาอิสลามเอาไว้ เช่น ในอินโดนีเซีย เจ้าอาณานิคมได้ลดอำนาจในการพิจารณาตัดสินของศาลศาสนาเหลือไว้เฉพาะการพิจารณาตัดสินที่เป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการสมัครที่คู่สมรสเป็นมุสลิมเท่านั้น ส่วนในเรื่องอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามคำสั่งของศาลธรรมดา¹ และในประเทศมาเลเซีย ศาลสูงมีสิทธิที่จะแย้งคำพิพากษาของศาลศาสนา ในครั้งดังกล่าวศาลศาสนามีอำนาจพิจารณาตัดสินที่เกี่ยวกับการสมัครและการหย่า คือ ศาล Quazi ส่วนศาล Tribunal The Watf Board มีอำนาจพิจารณาตัดสินที่เกี่ยวกับกองทุนบริจาคของมุสลิม²

เมื่อประเทศต่าง ๆ ได้รับเอกราช ได้มีนโยบายที่จะนำประเทศเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ โดยการปรับปรุงแนวทางพัฒนาทางด้านการเมืองและสังคมขึ้น ศาลศาสนาอิสลามก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบศาลของประเทศ³ และได้ปรับปรุงศาลศาสนาอิสลามให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม และให้มีความยุติธรรมยิ่งขึ้น ฉะนั้น เมื่อประเทศเหล่านั้นได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลาม ก็ได้ก่อตั้งศาลศาสนาอิสลามขึ้นด้วย ในที่นี้จะได้ศึกษาถึงศาลศาสนาอิสลามของประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ศรีลังกาและประเทศไทย เพื่อจะได้ทราบถึงโครงสร้างของศาสนาของแต่ละประเทศ

ก. ศาลศาสนาอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ ตามประมวลกฎหมายว่าด้วย สถานภาพบุคคลมุสลิมได้ก่อตั้งศาลศาสนา (Shariah Court) สำหรับการพิจารณาตัดสินตามกฎหมายอิสลามได้แบ่งออกเป็นสองศาล คือ

1. ศาลศาสนาอิสลามประจำภาค (Sharia Distric Court)
2. ศาลศาสนาอิสลามประจำท้องถิ่น (Sharia Cercuit Court)

¹Eustanul Arifin, the Administration of Shari'ah Laws in Indonesia p. 12.

²Ahmed Hilmy mohideen, Physical Organization of Shari'ah Court in Sri lanka, p. 1.

³Ibid, p. 2.

ศาลคำสอนทั้งสองและข้าราชการในสังกัดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศาลสูง¹ (Superme Court)

1. ศาลคำสอนอิสลามประจำภาค คือ ศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลประจำแต่ละภาค เพื่อพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก) เขตศาลคำสอนอิสลามประจำภาค ศาลคำสอนอิสลามประจำภาคตาม ประมวลกฎหมาย ว่าด้วย สถานภาพบุคคลมุสลิม ได้แบ่งศาลคำสอนอิสลามประจำภาคออกเป็น 5 ภาค โดยแต่ละศาลมีผู้พิพากษาประจำอยู่ 1 นาย แต่ละศาลมีเขตอำนาจศาล ดังนี้ คือ

- 1) ศาลคำสอนอิสลามประจำภาคที่ 1 มีเขตอำนาจศาลในจังหวัด Sulu
- 2) ศาลคำสอนอิสลามประจำภาคที่ 2 มีเขตอำนาจศาลในจังหวัด Tawi-

Tawi

3) ศาลคำสอนอิสลามประจำภาคที่ 3 มีเขตอำนาจศาลในจังหวัด Basilan, Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur, and the Cities of Dipolog, Pagadian and Zamboanga

4) ศาลคำสอนอิสลามประจำภาคที่ 4 มีเขตอำนาจศาลในจังหวัด Lanao del Norte and Lanao del Sur, and the Cities of Iligan and Marawi

5) ศาลคำสอนอิสลามประจำภาคที่ 5 มีเขตอำนาจศาลในจังหวัด Maguindanao North Cotabato and Sultan Kudarat, and the City of Cotabato²

ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้พิพากษาประจำศาล ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา ประจำศาลคำสอนอิสลามประจำภาค จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์³ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คือ นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

¹ มาตรา 137 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

² มาตรา 138 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 139 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

บทบัญญัติสำหรับการเป็นผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น (Court of First Instance) ตามกฎหมายว่าด้วย ข้าราชการตุลาการ (Judiciary Law) แล้วจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในกฎหมายอิสลาม¹

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลศาสนาอิสลามประจำภาค จะต้องดำรงตำแหน่งไปจนถึงอายุ 65 ปี หรือ จนกว่าไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้จะถูกปลดออก ในกรณีที่มีสาเหตุและพฤติการณ์เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น² ส่วนค่าตอบแทนของผู้พิพากษานั้น จะได้รับค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลชั้นต้น³

ค) เขตอำนาจศาลศาสนาอิสลามประจำภาคในฐานะศาลชั้นต้น (Original Jurisdiction) ศาลศาสนาอิสลามประจำภาค มีอำนาจในการพิจารณาคดีในฐานะที่เป็นศาลชั้นต้น ในกรณี ดังนี้

- 1) คดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองดูแล (Custody) ความปกครอง (Guardianship) การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy) ความเป็นบิดา มารดา (Paternity and filiation) ที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายนี้
- 2) คดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งและข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย ที่เป็นมุสลิม หนี้กรรม (Disposition) การพิสูจน์หนี้กรรม (Probate of Will) การแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- 3) การยื่นคำขอให้ศาลประกาศการล่าปลูญและการตาย และเพื่อขอยกเลิกหรือแก้ไขการจดทะเบียนของมุสลิมตามที่ได้กล่าวไว้ในประมวลกฎหมายนี้ ที่ว่าด้วยการจดทะเบียน

¹ มาตรา 140 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

² มาตรา 141 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 142 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

4) การฟ้องร้องทั้งหมดที่เกิดจากสัญญาตามประเพณี (Customary Contracts) ซึ่งมีคู่กรณีเป็นมุสลิม ถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะนำมาบังคับใช้ในกรณีเช่นนั้น และ

5) คำขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด (Mandamus) ข้อห้าม คำสั่งของศาลที่สั่งให้หรือห้ามมิให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด (Injunction) การอุทธรณ์ หมายที่ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่พนักงานส่งตัวผู้ถูกคุมขังไปให้ศาลพิจารณา (Habeas Corpus) และให้ออกหมายศาลต่าง ๆ¹

ง) อำนาจพิพากษาคดีอุทธรณ์ (Appellate Jurisdiction) ศาลคำสอนอิสลามประจำภาค นอกจากจะมีอำนาจพิพากษาคดีในฐานะศาลชั้นต้นสำหรับพิพากษาคดีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังต้องทำหน้าที่เป็นศาลอุทธรณ์สำหรับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลคำสอนอิสลามประจำท้องถิ่น (Sharia circuit court) และได้อุทธรณ์มาสู่ศาลคำสอนอิสลามประจำภาค โดยกฎหมายกำหนดให้

1) ศาลคำสอนอิสลามประจำภาคมีอำนาจในการพิพากษาคดีอุทธรณ์ (Appellate Jurisdiction) คดีทั้งหมดที่ได้พิพากษาพิพากษาในศาลคำสอนอิสลามประจำท้องถิ่นภายในเขตศาล (Territorial Jurisdiction) ของแต่ละภาค

2) ศาลคำสอนอิสลามประจำภาคจะต้องทำการพิพากษาคดีที่อุทธรณ์มาสู่ศาลคำสอนอิสลามประจำภาค โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและสำนวนคดี ตลอดจนรายงานการพิพากษาคดี (Memoranda) สำนวนความ (Brief) หรือคำแถลงการณ์ของคู่ความที่ได้ยื่นต่อศาลเพื่อทำการพิจารณา²

จ) คำพิพากษาถึงที่สุด (Finality of Decision) คำพิพากษาของศาลคำสอนอิสลามประจำภาค หรือคำพิพากษาในกรณีที่เป็นการพิพากษาคดีที่อุทธรณ์มาจากศาลคำสอน

¹ มาตรา 143 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

² มาตรา 144 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

อิสลามประจำท้องถิ่น ศาสนาอิสลามทั้งสองกรณียังถือว่าไม่ถึงที่สุด สามารถที่จะนำขึ้นสู่ศาลสูง เพื่อพิจารณาได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ¹

จ) ข้าราชการในสังกัดของศาลนาคอิสลามประจำภาค ศาลนาคอิสลามประจำภาค นอกจากจะมีผู้พิพากษา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี แล้วยังมีข้าราชการอื่น ๆ ในสังกัดด้วย สำหรับข้าราชการเหล่านี้ก็ต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้กับศาลชั้นต้น

บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยข้าราชการตุลาการ (Judiciary Law) ในประเด็น ที่เกี่ยวกับจำนวน คุณสมบัติ การแต่งตั้ง คำตอบแทนหน้าที่และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการ ในสังกัดชั้นต้นสามารถที่จะนำมา ใช้กับศาลศาลนาคอิสลามประจำภาคได้²

ข) วิธีพิจารณาคดี ในการพิจารณาคดีศาลศาลนาคอิสลามประจำภาคจะต้องดำเนิน วิธีพิจารณาคดีให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับพิเศษ (Special Rule) หรือวิธีพิจารณาที่ประกาศใช้ โดยศาลสูง³ ส่วนการนำกฎหมายอื่นมาใช้ในศาลศาลนาคอิสลามประจำภาคนั้น บทบัญญัติทั้งหลาย ที่เกี่ยวกับศาลชั้นต้นสามารถนำมาบังคับใช้ในศาลศาลนาคอิสลามประจำภาคได้เท่าที่ไม่ขัดกับประมวล กฎหมายนี้⁴

2. ศาลศาลนาคอิสลามประจำท้องถิ่น (Sharia Circuit Court) คือ ศาลที่มี เขตอำนาจศาลเดียวกันกับศาลศาลนาคอิสลามประจำภาค แต่ตั้งอยู่ต่างท้องที่ เพื่อทำการพิจารณา พิพากษาคดีตามกฎหมายอิสลามเฉพาะในเขตศาลของแต่ละศาลเท่านั้น สำหรับที่ตั้งของศาล ศาลนาคอิสลามประจำท้องถิ่น กฎหมายได้แบ่งให้เป็นไปตามเขตอำนาจของศาลศาลนาคอิสลาม ประจำในแต่ละเขต ดังนี้

ในเขตของศาลศาลนาคอิสลามประจำภาคที่ 1 จังหวัด Sulu มีศาลศาลนาคอิสลาม ประจำท้องถิ่น จำนวน 6 ศาล

¹ มาตรา 145 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานาภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

² มาตรา 146 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานาภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 148 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานาภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

⁴ มาตรา 148 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานาภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

ในเขตของศาลศาลนาอิสลามประจำภาคที่ 2 จังหวัด Tawi-Tawi มีศาลศาลนาอิสลามประจำท้องถิ่นจำนวน 8 ศาล

ในเขตของศาลศาลนาอิสลามประจำภาคที่ 3 จังหวัด Basilan; Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur and the City of Dipolog, pagadian and Zamboanga จำนวน 10 ศาล

ในเขตของศาลศาลนาอิสลามประจำภาคที่ 4 จังหวัด Lanao del North and del Sur and the Cities of Iligan and Marawi จำนวน 12 ศาล

ในเขตของศาลศาลนาอิสลามประจำภาคที่ 5 จังหวัด Maguindanao, North Cotabato and Sultan Kudarat and the city of Cotabato จำนวน 15 ศาล¹

ก) เขตศาล (Teritoria l Jurisdiction) เขตศาลของศาลนาอิสลามประจำท้องถิ่นว่าแต่ละศาลจะมีเขตศาลเพียงใดนั้น ศาลสูงจะได้กำหนดเขตศาลของแต่ละศาลเอาไว้โดยคำนึงสภาพที่ติดต่อกันทางภูมิศาสตร์ของเทศบาล (Municipalities) และเมือง รวมทั้งจำนวนประชากรมุสลิม²

ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้พิพากษาของศาลศาลนาอิสลามประจำท้องถิ่น ศาลศาลนาอิสลามประจำท้องถิ่นแต่ละศาลจะมีผู้พิพากษาประจำศาลที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์³ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ผู้พิพากษาประจำภาคศาลต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นประชาชนฟิลิปปินส์โดยกำเนิด มีอายุอย่างน้อย 25 ปี และได้ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการทางศาสนาและกฎหมายอิสลามโดยศาลสูงได้รับเข้า เป็นสมาชิกพิเศษของ เนติบัณฑิตยสภา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลศาลนา⁴

¹ มาตรา 150 (1) แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

² มาตรา 150 (2) แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 151 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

⁴ มาตรา 152 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์



สำหรับสถานภาพของผู้พิพากษาจึงได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายตราบเท่าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จนถึงอายุ 65 ปี หรือได้กลายมาเป็นผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะถูกปลดออกทันที ถ้าหากมีสาเหตุและพฤติการณ์เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับผู้พิพากษาของศาลเทศบาล (Municipal Circuit Court)¹ ส่วนคำตอบแทนผู้พิพากษาของศาลศาลาอิสลามประจำท้องถิ่นมีสิทธิที่จะได้รับคำตอบแทนและเอกสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้พิพากษาของศาลเทศบาล²

ค) เขตอำนาจศาล (Jurisdiction) ศาลศาลาอิสลามประจำท้องถิ่นมีอำนาจพิจารณาคดีเบื้องต้น (Original Jurisdiction) ดังต่อไปนี้

- 1) คดีทั้งหมดที่เป็นความผิดและมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายนี้
- 2) การฟ้องคดีแพ่งทั้งหมด (All Civil action) ระหว่างคู่ความที่เป็นมุสลิม หรือคู่ความได้ทำการสมัครตาม มาตรา 13 ว่าด้วย ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับ

(ก) การแต่งงาน
(ข) การหย่าตามประมวลกฎหมายนี้
(ค) สินสอดตามประเพณี (Customary Dower) หรือ Mahr
(ง) ทรัพย์สิน (Disposition) และการแบ่งทรัพย์สินเนื่องจากการหย่า

(จ) คำอุปการะเลี้ยงดูและการให้เพื่อปลอบขวัญเนื่องจากการหย่า (Consolatory Gifts-on Divorce) และการชดเชยตามสิทธิเกี่ยวกับการสมรส (Restitution of marital rights)

(ฉ) คดีทั้งหมดที่เป็นข้อขัดแย้ง เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของชุมชนมุสลิม³

ง) ข้าราชการในสังกัดของศาลศาลาอิสลามประจำท้องถิ่น ศาลศาลาอิสลามประจำท้องถิ่น นอกจากจะมีผู้พิพากษาซึ่งทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีแล้วยังมีข้าราชการในสังกัด

¹ มาตรา 153 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

² มาตรา 154 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 155 แห่ง ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

ของศาลด้วย สำหรับข้าราชการเหล่านี้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้สำหรับศาล
เทศบาล

บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยข้าราชการตุลาการในประเด็นที่เกี่ยวกับจำนวนคุณสมบัติ
การแต่งตั้ง ค่าตอบแทน อำนาจหน้าที่และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการในสังกัด ศาลเทศบาล
สามารถนำมาใช้กับข้าราชการในสังกัดศาลศาสนาอิสลามท้องถิ่นได้¹

จ) วิถีพิจารณาคดี ในการพิจารณาคดี ศาลศาสนาอิสลามประจำท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการพิจารณาคดีไปตามกฎเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวกับวิถีพิจารณาที่ประกาศใช้โดยศาลสูง²
สำหรับการนำเอากฎหมายอื่นมาใช้ในศาลศาสนาอิสลามประจำท้องถิ่นนั้น บทบัญญัติทั้งหมดของ
กฎหมายที่ใช้กับศาลเทศบาล สามารถที่จะนำมาใช้ในศาลศาสนาอิสลามประจำท้องถิ่นได้เท่าที่
ไม่ขัดกับประมวลกฎหมายนี้³

ข. ศาลศาสนาอิสลาม (Shariah Court) ในสิงคโปร์

การใช้กฎหมายอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลาม ได้กำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามเอาไว้อย่างชัดเจน คือ ได้ก่อตั้งสถาบันต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลาม รวมทั้งวิธีการดำเนินการบริหารกฎหมายอิสลามเอาไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ก่อตั้งศาลเพื่อทำการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายอิสลามเรียกว่า
Shariah Court

โดยได้กำหนดวิธีการบริหารกฎหมายอิสลามเอาไว้เป็นการเฉพาะ แต่ในที่นี้จะได้กล่าว
ถึงเฉพาะที่สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เขตอำนาจศาล (Jurisdiction) ศาลศาสนาอิสลามมีเขตอำนาจ
พิจารณาคดีทั่วเกาะสิงคโปร์ โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลศาสนาอิสลามจะต้องได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานาธิบดีแห่งสิงคโปร์⁴

¹ มาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลสมรสของฟิลิปปินส์

² มาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลสมรสของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลสมรสของฟิลิปปินส์

⁴ มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

ศาลคำสอนอิสลามมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มุสลิม เป็นคู่ความทั้งสองฝ่าย หรือคู่ความที่ทำการสมรสภายใต้หลักกฎหมายอิสลามและ เป็นข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับ

การแต่งงาน

การหย่า ในกรณีี่ตามกฎหมายอิสลามเรียกว่า Fasakh, Cherai Taalik, Kholo and Talak

การหยัน การแต่งงานที่ตกเป็นโมฆะ หรือการแยกกันอยู่ตามกฎหมาย (Judicial Separation)

พินัยกรรม หรือการแบ่งทรัพย์สินเนื่องจากการหย่า หรือ

การชำระค่าผูกมัดที่เกิดจากการสมรส (Payment of Mas-kahwin) ค่าอุปการะ เลี้ยงดูและการให้เพื่อปลอบขวัญเนื่องจากการหย่า (Consolatory Gifts หรือMatta'ah)¹

2. การรับฟังพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลาม ได้ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานเอาไว้ ดังนี้ คือ

ก) ศาลต้องนำเอากฎหมาย ว่าด้วยพยานหลักฐานที่บังคับใช้อยู่ในสิงคโปร์ ขณะนั้นมาเป็นหลักในการพิจารณาคดี แต่ก็ไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องนำเอามาใช้อย่างเคร่งครัด

ข) ศาลคำสอนอิสลาม สามารถที่จะจัดการให้การสาบาน การรับรอง พยานหลักฐาน (Affirmation) ให้เป็นไปตามวิธีธรรมดาที่เกี่ยวกับการสาบาน การรับรอง พยานที่จะเป็นข้อผูกมัดแก่มุสลิม แต่ถ้าหากศาลมีเหตุผลพิเศษจะงดเว้นไม่ให้มีการสาบาน หรือนำหลักฐานมาเพื่อให้พยานรับรองก็ได้

ค) ถ้าหากศาลเห็นว่าพยานจงใจที่จะให้หลักฐานปลอมในการพิจารณาคดีใด ๆ ศาลสามารถที่จะรายงานเรื่องนี้แก่พนักงานอัยการ²

3. อำนาจของศาลเกี่ยวกับการรับฟังพยาน ศาลคำสอนอิสลามมีอำนาจในการรับฟังพยานหลักฐาน คือ

¹ มาตรา 35 (2) แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

² มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

ก) จัดหาและรับฟังพยานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพยานเอกลสารหรือพยานบุคคล และซักถามพยานทุกคนที่ศาลเห็นว่ามีความจำเป็น

ข) เรียกพยาน ทั้งพยานเอกลสารและพยานบุคคลเพื่อให้สาบานตน หรือรับรองว่าเป็นพยานหลักฐานจริง

ค) ออกหมายเรียกบุคคล เพื่อปรากฏต่อหน้าศาล หรือส่งมอบพยานหลักฐาน หรือเพื่อให้หน้าเอกลสาร หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเขา หรือเพื่อสอบถามในฐานะพยาน

ง) ออกหมายจับ (Issue a warrant) เพื่อบังคับการมาศาล (Attendance) แก่ผู้ที่ได้รับหมายเรียก แล้วไม่กระทำตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุอันสมควร และสั่งให้เสียค่าปรับเนื่องจากการไม่มาศาล หรือเนื่องจากการปฏิเสธหมายศาล¹

4. การอุทธรณ์ (Appeal) การใช้กฎหมายอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลาม คู่กรณีสามารถที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลคำล่านา โดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Board)

สำหรับคดีที่จะอุทธรณ์ขึ้นมากู่คณะกรรมการอุทธรณ์นั้น จะต้องเป็นไปตามกรณี ดังต่อไปนี้

ก) คดีที่จะสามารถอุทธรณ์ได้ คือ

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากคำพิพากษาในทุกคดีที่อาจคิดเป็นมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 25 ดอลลาร์

2) ในทุกคดีที่มีคำพิพากษาในเรื่องสถานภาพของบุคคล (Personal status)

3) ทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับค่าอุปการะเลี้ยงดูของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย (Maintenance of dependants) โดยเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษา

4) คดีอื่น ๆ สามารถจะอุทธรณ์ได้ ถ้าหากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอุทธรณ์

¹ มาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

ข) คดีที่อุทธรณ์หรือคดีที่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์ จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน

1 เดือน นับจากวันที่มีคำพิพากษา สำหรับข้อกำหนดนี้ถ้าหากว่าคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่า มีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ์ก็สามารถที่จะอนุญาตให้อุทธรณ์ได้หลังจากที่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ 1 เดือนนั้นสิ้นสุดลง

ค) ผู้ที่อุทธรณ์จะต้องส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยผ่าน เลขานุการของคณะกรรมการอิสลามและสิ่งเกี่ยวข้องความทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี อุทธรณ์

ง) ประธานาธิบดีโดยการแนะนำ ของคณะกรรมการอิสลาม จะได้เสนอ รายชื่อมุสลิมอย่างน้อย 7 คน เพื่อประกอบขึ้นเป็นคณะบุคคล ประธานคณะกรรมการอิสลามจะ ได้เลือกคณะบุคคลนี้ 3 คนเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ในแต่ละคดีเป็นครั้ง คราวไป และประธานกรรมการอิสลามเป็นผู้ เลือกผู้หนึ่งผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์

จ) คณะกรรมการอุทธรณ์สามารถที่จะพิพากษาขึ้น หรือกลับคำพิพากษา หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษา และมีอำนาจที่จะกระทำการต่าง ๆ อย่างศาลศาลนา หรือ ส่งให้พิจารณาคดีใหม่

ฉ) คำตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือว่าสิ้นสุด¹ นอกจากนั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ยังมีหน้าที่จะพิจารณาอุทธรณ์คำชี้ขาดของ Kathi หรือ Niab Kathi ที่ ปฏิเสธการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าตาม มาตรา 98 และได้อุทธรณ์ ขึ้นมาสู่คณะกรรมการอุทธรณ์²

ค. ศาลศาลนาอิสลามในประเทศศรีลังกา

สำหรับการบริหารกฎหมายอิสลามในศรีลังกานั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติ กล่าวคือ กฎหมายอิสลามถือว่า เป็นระบบกฎหมายหนึ่งของศรีลังกาที่นำมาบังคับใช้แก่ชาวมุสลิม แต่ไม่มี ศาลศาลนาอิสลามที่จะเป็นผู้บริหารกฎหมายอิสลาม แต่ได้ใช้ศาลแห่งที่มีผู้พิพากษา เป็นชาว อังกฤษ

¹ มาตรา 55 แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

² มาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

และไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้พิจารณาคดี ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าผู้พิพากษาเหล่านั้นแทบจะไม่ได้ถือเอาหลักกฎหมายอิสลามมาใช้เลย¹ ในตอนแรกศาลแพ่งจะเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลามในนามของศาลท้องถิ่น (District Court) และ Court of request and the Magistrates Court ต่อมาภายหลังจึงได้มีการก่อตั้งศาลขึ้นมาสองศาลเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม ซึ่งศาลทั้งสองนี้สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นศาลศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง คือ Quazi court ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลามในขอบเขตของการสมรสและการหย่าของมุสลิม และอีกศาลหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกองทุนบริจาต (the Wakf Board) ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาคดีในขอบเขตที่เกี่ยวกับการบริจาต และในที่สุดศาลศาสนาอิสลามก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบศาลในประเทศศรีลังกา² ดังรายละเอียดที่จะได้ศึกษา ต่อไปนี้

1. ศาลศาสนาอิสลาม ตามกฎหมายที่ว่าด้วยการสมรสและการหย่าของมุสลิม (Muslim Marriage and Divorce Registration Ordinance, No.27) ได้ก่อตั้งสำนักงาน Quazi หรือ Kathis ขึ้น ทำหน้าที่อย่างศาลศาสนาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสมรส การหย่าและอื่น ๆ³ และได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาอิสลามกระทำหน้าที่ในฐานะอย่างทางราชการ โดยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน เพื่อจดทะเบียนการสมรสของมุสลิมทั้งหมด โดยแต่งตั้ง Quazi หรือ Kathis ตลอดทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่ได้ส่วนและอนุมัติ การหย่าตามกฎหมายอิสลาม และให้ความช่วยเหลือคู่สมรสในด้านอื่น ๆ ด้วย ตามกฎหมายฉบับนี้นอกจากจะได้ตั้งศาล Quazi แล้ว ยังได้ก่อตั้งศาลอุทธรณ์พิเศษ (Special Court of Appeal) ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการ Quazi (Board of Quazi) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์คำตัดสินของ Quazi⁴

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shari'ah Court In Sri Lanka, 1st Asean Shari'ah Administrators Conference Workshop, August 7-11, 1983, Manila Philippines.

² Ibid, p.1.

³ Ibid, p. 17.

⁴ Ibid.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการแต่งงานและการหย่า ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 1951 ได้แก้ไข
 กฎีกา ว่าด้วยการสมรสและการหย่าของมุสลิม ฉบับที่ 27 ปี ค.ศ. 1929 แต่ยังคงระบบศาล
 Quazi เอาไว้¹

ก) ศาล Quazi ในปัจจุบันในศรีลังกามีศาล Quazi อยู่ประมาณ 52
 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งมีเขตอำนาจศาลแตกต่างกันไปจากศาลท้องถิ่น² ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) การแต่งตั้ง Quazi Quazi จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
 การส่งเสริมตุลาการ (Judicial Services Commission) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่
 มีอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการแต่งตั้งผู้พิพากษาทั่วประเทศ³

2) คุณสมบัติ Quazi จะได้รับการคัดเลือกมาจากชายมุสลิมที่
 บรรลุนิติภาวะ มีความเหมาะสมและเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายมีแนวโน้ม
 ที่มักจะได้รับการแต่งตั้ง เพราะเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมทางด้านนิติศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับ
 กฎหมายอิสลาม กฎหมายวิธีพิจารณาและกฎหมายพยาน ซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะนำ
 มาใช้ในศาล Quazi โดยปริยาย⁴

3) หน้าที่ของ Quazi ตามกฎีกา ว่าด้วยการแต่งงานและการ
 หย่า ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 1951 ได้กำหนดหน้าที่ของ Quazi เอาไว้ ดังนี้

(ก) เป็นผู้ไต่สวนคำขอหย่า ไม่ว่าจะโดยสามีหรือภรรยา
 เป็นผู้ขอหย่า และทำการไกล่เกลี่ยคู่กรณีก่อนจะมีคำสั่งให้หย่า

(ข) วินิจฉัยข้อเรียกร้องของภรรยา เกี่ยวกับทรัพย์สินของสามี
 ที่ต้องชำระแก่ภรรยา

(ค) วินิจฉัยข้อเรียกร้องของภรรยาและบุตร เกี่ยวกับค่าเลี้ยงดู

¹Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shari'ah Court
In Sri Lanka, 1st Asean Shari'ah Administrators Conference Workshop,
 August 7-11, 1983, Philippines.

²Ibid. p. 17.

³Ibid.

⁴Ibid.

(ง) ให้คำยินยอมในการล้มละลายของฝ่ายหญิงในกรณีที่วาสีไม่
ได้ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผล

(จ) ในบางกรณี Quazis อาจเรียกร้องให้ใช้เงินค่า
เลี้ยงดูที่ถึงกำหนดต้องชำระแก่ภรรยาหรือบุตรซึ่งได้ดำเนินการฟ้องร้องกันที่ศาลแล้ว และดำเนินการ
การจ่ายเงินคืนแก่ผู้เรียกร้อง

(ฉ) ดำเนินการไต่สวนคำร้องของภรรยา หรือภรรยาผู้ที่
ได้หย่าแล้ว เพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายในระหว่างการคลอดบุตร

(ช) ดำเนินการไต่สวนคำร้องเพื่อให้ดำเนินการไกล่เกลี่ย
หรือให้ประกาศว่า การล้มละลายนั้นเป็นโมฆะ¹

4) เขตอำนาจศาล เว้นแต่มีกฎหมายอื่นกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะ
ศาล Quazi มีอำนาจที่จะทำการไต่สวนและวินิจฉัยในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ในการ
ล้มละลายและการหย่าของมุสลิม หรือเรื่องที่อยู่ในเนื้อหาเกี่ยวกับการล้มละลายและการหย่า²

5) การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาล Quazi ถ้าผู้กรณีเห็นว่า ไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของ Quazi มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นภายใน 30 วัน นับแต่มีคำสั่ง
โดยอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ Quazi (Board of Quazi) ที่ตั้งอยู่ในโคลัมโบ³

ข) คณะกรรมการ Quazi (Board of Quazi)

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการ Quazi คณะกรรมการประกอบไปด้วย
ด้วยชาวมุสลิม 5 คน ที่มีความเหมาะสมและมีความรอบรู้โดยรับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมตุลาการ (Judicial Services commission)⁴

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shari'ah Court
In Sri Lanka, 1st Asean Shari'ah Administrators Conference Workshop,
August 7-11, 1983, Philippines, p.18.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

2) การพิจารณาคดี คณะกรรมการ Quazi มีอำนาจที่จะสั่งให้ดำเนินการพิจารณาคดีใหม่ หรือยกเลิกคำสั่งที่ได้ดำเนินการพิจารณาโดย Quazi คำสั่งของคณะกรรมการต้องทำเป็นคำพิพากษา ซึ่งนับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการดังกล่าวได้กล่าวอ้างถึงหลักกฎหมายอิสลาม กฎหมายวิธีพิจารณาและได้อุทธรณ์ว่างของกฎหมาย รายงานคำพิพากษาของคณะกรรมการได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี โดยถือเป็นบรรทัดฐานที่ต้องผูกมัดในการตีความเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กฎหมายอิสลามได้เจริญก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างโดดเด่นในยุคปัจจุบัน¹

3) การอุทธรณ์คำพิพากษา สำหรับการอุทธรณ์คำพิพากษาของคณะกรรมการกระทำได้โดยการอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ และฎีกาต่อไปยังศาลสูงได้อีกด้วย²

2. คณะกรรมการบริจาคตาน (Wakf Board) นอกเหนือจากศาลคำสอนอิสลามที่มีอำนาจพิจารณาคดีในเนื้อหาของกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวข้องครบครันหมดแล้ว ในศรีลังกา ยังได้ก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่บริหารหรือควบคุมคำสอนสมบัติที่ประชาชนมุสลิมได้อุทิศให้เป็นคำสอนสมบัติ อำนาจการบริหารและควบคุมคำสอนสมบัตินี้เป็นเอกเทศต่างหากจากศาลคำสอนอิสลาม³

คณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารและควบคุมคำสอนสมบัติแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ คณะกรรมการกองทุนบริจาคต (Wakf Board) กับศาลอุทธรณ์กองทุนบริจาคต (Wakf Tribunal of Appeal)

ก) คณะกรรมการกองทุนบริจาคต คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานของกองทุนบริจาคตทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยมัลลียัต กองทุนการกุศล (Charitable Trust)

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shari'ah Court In Sri Lanka, 1st Asean Shari'ah Administrators Conference Workshop, August 7-11, 1983, Philippines, p. 18.

² Ibid,

³ Ibid, p. 13.

สถานที่สักการะบูชาทางศาสนา (Religious Shrines) และที่พักอาศัย (Resorts)¹
สมาชิกของคณะกรรมการกองทุนบริจาคมีจำนวน 7 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบในกิจการศาสนาอิสลาม²

ข) ศาลอุทธรณ์กองทุนบริจาค ศาลนี้ทำหน้าที่รับการพิจารณาอุทธรณ์จาก
กองทุนบริจาค ผู้พิพากษาของศาลนี้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมตุลาการ (The
Judicial services commission) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในการแต่งตั้งผู้พิพากษา³

ง. ศาลศาสนาอิสลามในประเทศไทย การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา
และสตูล พ.ศ. 2489 ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นแต่เพียงได้ยอมรับให้นำเอากฎหมายอิสลามมา
บังคับแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัวและมรดกเท่านั้น โดยไม่ได้ก่อตั้ง
ศาล และกำหนดวิธีพิจารณาคดีสำหรับศาลขึ้นเป็นพิเคา และไม่ใช่อีกเทศจากศาลแพ่ง
กล่าวคือ ได้กำหนดให้ศาลขึ้นต้นในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูลเป็นผู้พิจารณาคดี
ตามกฎหมายอิสลาม ดังนั้น ศาลขึ้นต้นในเขตจังหวัดดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นศาลศาสนาอิสลาม
โดยมีตะโต๊ะยุติธรรมประจำแต่ละศาลเป็นผู้ชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม

เนื่องจากมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วย การใช้กฎหมายอิสลาม ฯ ใช้คำว่า
"ศาลขึ้นต้น" มิได้ใช้คำว่า "ศาลจังหวัด" ฉะนั้น จึงไม่หมายความว่าเฉพาะศาลจังหวัดเท่านั้น
แต่หมายความว่าศาลอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในฐานะเป็นศาลขึ้นต้น เช่น ศาลแขวง ศาลคดีเด็กและ
เยาวชนหรืออื่น ๆ ถ้าจะมีขึ้นในโอกาสหน้าหากว่าศาลนั้นมีอำนาจพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
ครอบครัวมรดก แต่เมื่อพิจารณาถึงศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีใน 4 จังหวัด ก็มีแต่

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shari'ah Court
In Sri Lanka, 1st Asean Shari'ah Administrators Conference Workshop,
August 7-11, 1983, Philippines, p.13.

² Ibid, p. 11.

³ Ibid, p. 13.



ศาลจังหวัดเท่านั้น ฉะนั้น ศาลจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล จึงทำหน้าที่เป็นศาล
ศาสนาอิสลาม โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับศาลและวิธีพิจารณา เป็นไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ

1. เขตอำนาจศาล เขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม
นั้น หมายถึงเขตอำนาจศาลจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล การที่จะพิจารณาว่าคดีใด
ศาลสามารถจะนำเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่ง ว่าด้วยครอบครัว
มรดกนั้น จะต้องพิจารณาว่า

- ก) เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก
- ข) มีคู่ความเป็นมุสลิมทั้งโจทก์และจำเลย หรือเป็นผู้เสนอคำขอในคดี
ไม่มีข้อพิพาท
- ค) ต้องเป็นคดีที่อยู่ในเขตของศาลจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและ
สตูล¹ ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในศาลจังหวัดอื่นนอกจาก 4 จังหวัดดังกล่าวแล้ว แม้โจทก์ จำเลย
ผู้ร้องขอหรือเจ้ามรดกจะเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บังคับ จะใช้กฎหมายอิสลามบังคับไม่ได้²

¹ฎีกาที่ 1406/2513 โจทก์และจำเลยเป็นอิสลามคำสันนิษฐานในเขตจังหวัดปัตตานี พิพาท
กันในเรื่องตั้งผู้จัดการมรดก นับว่าเป็นคดีพิพาทด้วยเรื่องมรดกอิสลามคำสันนิษฐาน จึงตกอยู่ภายใต้
บังคับแห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามมาตรา 3

²ฎีกาที่ 102/2517 แม้โจทก์และจำเลยจะเป็นอิสลามคำสันนิษฐานและพิพาทกันในคดีแพ่ง
เกี่ยวกับเรื่องมรดกอิสลามคำสันนิษฐานก็ตาม แต่คดีมิได้เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา
และสตูล แล้วจะนำเอาหลักการศาสนาอิสลาม หรือกฎหมายอิสลามมาใช้บังคับในการแบ่งมรดก
มรดกแทนบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. ว่าด้วยการแบ่งมรดกไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติ
ใน มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส
ยะลาและสตูล พ.ศ. 2489 ฉะนั้น ถ้ามีการนำวิธีการแบ่งมรดกตามหลักการศาสนาอิสลาม
มาใช้ในการแบ่งมรดกก็จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ มาตรา 1750 ด้วยจึงจะ
มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ส่วนการพิจารณาคดีว่า คดีใดจะอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดทั้ง 4 นั้น ต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4¹ เมื่อพิจารณาได้ว่าเป็นคดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดทั้ง 4 ศาลแล้ว ศาลก็สามารถนำเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้โดยไม่คำนึงถึงว่าทรัพย์สินที่พิพาทกันนั้นจะจำกัดว่าต้องอยู่ในเขตจังหวัดทั้ง 4 หรือไม่ อย่างไรก็ตามในข้อนี้ไม่มีคำพิพากษาฎีกาเป็นบรรทัดฐาน แต่คำพิพากษาซึ่งวินิจฉัยตามสำรตราของกระทรวงยุติธรรมที่ 30/4353 คือ คำพิพากษาฎีกาที่ 90/2483 นายหวันเต๊ะ หวังปูเต๊ะ โจทก์ นายเอ เอช. ดูก หลวงประกอบนิติสาร จำเลย วินิจฉัยว่า กระทั่งความตามสำรตราฉบับนี้มีความหมายครอบคลุมถึงทรัพย์สินรดกทุกอย่าง โดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ประการใด และไม่ปรากฏข้อยกเว้นว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ที่ใด และจะต้องจัดการตามกฎหมายอื่นประการใด ฉะนั้น จึงถือว่าสำรตราฉบับนี้มีความครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินรดกทุกอย่าง กับคำพิพากษาฎีกาที่ 1286/2481 นางหวันเต๊ะ หวังปูเต๊ะ โจทก์ นายเอ เอช. ดูก หลวงประกอบนิติสาร จำเลย ซึ่งวินิจฉัยทำนองเดียวกันว่า ศาลจังหวัดสุลตได้ตั้งผู้จัดการมรดกเป็นอิสลามคำสนิก เมื่อโจทก์เห็นว่าการจัดการมรดกไม่ถูกต้องตาม

¹ มาตรา 4 เว้นแต่จะให้กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การยื่นคำฟ้องนั้นต้องอยู่ในบังคับแห่งบัญญัติ ดังต่อไปนี้

1. คำฟ้องร้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ หรือประโยชน์ใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านั้น ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์สินเหล่านั้นตั้งอยู่ในเขตศาล แต่ถ้าโจทก์มีความประสงค์จะยื่นคำฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น ๆ จะเป็นการสะดวก ศาลจะใช้ดุลพินิจอนุญาตให้โจทก์ยื่นคำฟ้องตามที่ขต้นนั้นก็ได้

2. คำฟ้องอื่น ๆ นอกจากนี้ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล แต่ถ้าโจทก์มีความประสงค์จะยื่นคำฟ้องต่อศาลที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนั้น หรือในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท ถ้าโจทก์มีความประสงค์จะยื่นคำฟ้องต่อศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น เมื่อโจทก์ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาคดีในศาลนั้น ๆ จะเป็นการสะดวก ศาลจะใช้ดุลพินิจให้โจทก์ยื่นคำฟ้องตามที่ขอนั้นได้

หน้าที่ต้องว่ากล่าวต่อศาลจังหวัดสุล การที่มีทรัพย์สินบางอย่างเป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ในจังหวัดพระนครนั้นไม่เป็นเหตุให้จำกัดอำนาจศาลจังหวัดสุลในเรื่องมรดกนี้ และไม่ทำให้ศาลแห่งมีอำนาจรับคดีไว้พิจารณาได้

เมื่อพิจารณาข้อความของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ. 2489 กับกฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเขตหัวเมือง ร.ศ. 120 และสารตราของกระทรวงยุติธรรมที่ 30/4353 จะเห็นว่า มีข้อความในแบบเดียวกัน คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวน่าจะใช่เป็นบรรทัดฐานได้ ทั้งความประสงค์ของกฎหมายเรื่องนี้ก็มุ่งหมายให้ใช้สิทธิประเพณีอิสลามในเรื่องครอบครัวมรดกแก่ผู้บังคับศาลนาอิสลามที่อยู่ในเขตจังหวัดทั้ง 4 ฉะนั้นจึงเห็นว่าไม่มีข้อจำกัดถึงเรื่องทรัพย์สินว่าจะต้องอยู่ในจังหวัดดังกล่าวนี้ด้วย¹ และในกรณีเดียวกันถ้าหากกรณีนั้นมีคู่ความเป็นมุสลิม และพิจารณาได้ว่าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลใน 4 จังหวัดดังกล่าวที่จะพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามเขตอำนาจที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว ศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัด ก็สามารถนำเอากฎหมายอิสลามมาใช้บังคับเกี่ยวกับคดีนั้น โดยไม่คำนึงว่าคู่ความนั้นจะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตท้องที่ของ 4 จังหวัดนั้นหรือไม่²

จะเห็นว่าในการใช้กฎหมายอิสลามตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูลนั้น ได้ถือเอาเขตอำนาจศาลเป็นสาระสำคัญ คือ ถ้าหากเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นของ 4 จังหวัดสามารถที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ศาลก็ต้องนำเอากฎหมายอิสลามมาใช้บังคับแก่คดีนั้น โดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับคดี หรือโจทก์จำเลย จะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 4 จังหวัด หรือไม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม ไม่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลชั้นต้นในการพิจารณา

¹พิพนธ์ สักการากร, กฎหมายอิสลาม, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 319.

²อุทัย บุรณสมภพ, กฎหมายพิเศษใน 4 จังหวัดภาคใต้, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 341 (คัดจากตุลสห เล่มที่ 4 ปีที่ 15 กรกฎาคม - สิงหาคม 2521)

พิจารณาคดีเอาไว้งดต้องพิจารณาตามเขตอำนาจศาลจังหวัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 ซึ่งตามมาตรา 4 นี้ การฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์นั้นให้เล่นนอกศาลฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์เหล่านั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ในกรณีนี้ไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของโจทก์ จำเลย และในการเล่นนอกศาลคดีซึ่งมิได้เกี่ยวกับทรัพย์ให้เล่นนอกศาลฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคดีที่ฟ้องร้องกันจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์ หรือสืบเนื่องจากทรัพย์บ้าง แต่มิได้พิจารณาในเรื่องนั้นโดยตรง ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่ต้องคำนึงถึงว่าทรัพย์นั้นจะอยู่ในเขตอำนาจของศาล 4 จังหวัด หรือไม่ ในกรณีฟ้องเรียกทรัพย์มรดกที่อยู่ในเขตของศาล 4 จังหวัด แต่มีทรัพย์บางอย่างอยู่นอกเขตศาลดังกล่าว ทรัพย์ที่อยู่นอกศาลก็ตกอยู่ภายใต้หลักกฎหมายอิสลาม การแบ่งปันทรัพย์มรดกก็ต้องถือตามกฎหมายอิสลาม

การที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ไม่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับศาลที่จะทำการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายอิสลามเอาไว้เป็นพิเศษ เป็นผลให้ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเฉพาะเขตอำนาจศาล ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะอาจจะกระทบกระทั่งจนถึงสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่เป็นมุสลิมได้ ซึ่งถ้าหากนำเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งใช้ควบคู่กับประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับกับกรณีของศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายอิสลามในฐานะศาลคำสอนอิสลาม สิ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่เป็นมุสลิม กล่าวคือ ถ้าพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป มีผลบังคับครอบคลุมไปทั่วประเทศ ไม่ว่าทรัพย์สินหรือจำเลยจะอยู่นอกเขตของศาล 4 จังหวัดดังกล่าวหรือไม่ก็ไม่ทำให้สิทธิตามกฎหมายแตกต่างกันแต่ประการใด เพราะไม่ว่าทรัพย์หรือจำเลยจะตกอยู่ ณ ที่ใด ก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกันหมด แต่ถ้าหากพิจารณาตามกฎหมายอิสลาม ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์ แต่ทรัพย์สินอยู่นอกเขตอำนาจของศาลทั้ง 4 ก็ไม่สามารถนำเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้กับคดีได้ แม้ว่าโจทก์จำเลยจะเป็นมุสลิม มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 4 จังหวัดก็ตาม เช่นการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกที่อยู่นอกเขตศาล 4 จังหวัด ทายาทไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นทายาทตามกฎหมายแพ่งแล้วก็ไม่มียกเว้นที่จะเกี่ยวข้องในคดีนั้น หรือไม่มียกเว้นที่จะเข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพย์สินมรดกที่อยู่ในเขตศาล 4 จังหวัดนั้นได้ ในทางตรงข้ามการฟ้องคดีเรียกทรัพย์สินมรดก หรือการจัดการทรัพย์สินมรดกที่อยู่ในเขต 4 จังหวัด แต่โจทก์หรือจำเลยเป็นมุสลิมที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตศาลดังกล่าว ก็ไม่สามารถนำเอากฎหมายอิสลามไปใช้บังคับแก่คดีได้ หรือในกรณีที่เป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับสิทธิทางครอบครัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (2) จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาล ดังนั้น ภูมิลำเนาของจำเลยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สิทธิอันเกิดจากสถานะทางครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ถ้าหากจำเลยมีภูมิลำเนาในเขต 4 จังหวัด ก็ต้องบังคับไปตามสิทธิตามกฎหมายอิสลาม แต่ถ้าหากว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขต 4 จังหวัด ก็ต้องบังคับไปตามสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้เป็นจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องด้วยครอบครัวมรดกต้องย้ายภูมิลำเนาออกนอกเขตศาล 4 จังหวัด เมื่อเห็นว่าถ้าหากมีการบังคับสิทธิตามกฎหมายอิสลามแล้วตนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ โดยที่โจทก์ไม่สามารถฟ้องคดีในศาล 4 จังหวัดได้

จากการที่จำเลยที่เป็นมุสลิมย้ายภูมิลำเนาออกจาก 4 จังหวัด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใช้กฎหมายอิสลามในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของตนนี้ เป็นปัญหาที่ได้หยิบยกขึ้นมาอภิปรายในการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล โดยมีข้อเสนอแนะจากการสัมมนาฯ ให้กระทรวงยุติธรรมรับปัญหานี้ไปพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ควรปล่อยให้สิทธิเสรีภาพของชาวไทยมุสลิมที่จะย้ายภูมิลำเนาของตนได้โดยเสรี ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรต่อไป¹

จากความเห็นของกระทรวงยุติธรรมนี้ ผู้ทนายนิพนธ์เห็นว่ายังไม่ถูกต้องตรงกับปัญหา เพราะการที่จำเลยที่เป็นมุสลิมย้ายภูมิลำเนาเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้ตามกฎหมายอิสลามนั้น เป็นผลที่เกิดจากปัญหาของการใช้กฎหมายอิสลามเท่านั้น จึงไม่เป็นปัญหาโดยตรง แต่ปัญหาที่แท้จริง คือการไม่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามเอาไว้ โดยเฉพาะไม่ได้

1

การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล
กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 147.

ก่อตั้งสถาบันเพื่อการบริหารกฎหมายอิสลามและกระบวนการดำเนินการบริหารกฎหมายอิสลาม แต่กลับให้ศาลแพ่งเป็นผู้บริหารกฎหมายอิสลามแทน โดยดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดีไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การใช้กฎหมายอิสลามจึงเกิดปัญหาติดตามมา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งย่อมเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป แต่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับกฎหมายอิสลามที่เป็นกฎหมายเฉพาะ ฉะนั้น การที่จะแก้ไขปัญหาก็ต้องแก้ไขที่บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม มิใช่แก้ที่ปัญหาที่มูลสมัยัญมึสำเนา เพราะการย้ายมึสำเนาเป็นสิทธิของประชาชนชาวไทยทุกคน จะกล่าวว่ามึสมัยัญมึสำเนาเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายอิสลามไม่ได้ เพราะประชาชนชาวไทยทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้นได้

2. ตะโตะะยุติธรรม ตะโตะะยุติธรรมตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำแปลว่า ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิสลาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม¹ ตะโตะะยุติธรรมจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการการใช้กฎหมายอิสลาม เช่นเดียวกับผู้พิพากษาทั่วไปที่มีบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการทางศาล การบริหารกฎหมายอิสลามจะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตะโตะะยุติธรรม ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สถานภาพ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกและการแต่งตั้ง และวิธีการที่ตะโตะะยุติธรรมพิจารณาตัดสินรายละเอียดต่อไปนี้

ก) สถานภาพของตะโตะะยุติธรรม ตะโตะะยุติธรรมนั้นเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับตะโตะะยุติธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 คือ

¹ พระราชบัญญัติว่าด้วย การใช้กฎหมายอิสลามฯ มาตรา 4 การพิจารณาคดีในศาลขึ้นต้นตามความในมาตรา 3 ให้ตะโตะะยุติธรรม 1 นาย นั่งพิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษา

ให้ตะโตะะยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม และลงลายมือชื่อในคำพิพากษาที่พิพากษาตามคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นด้วย

คำวินิจฉัยชี้ขาดของตะโตะะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้น

โดย ผู้ใช้ทั่วไป

ดาวน์โหลดเมื่อ 21/08/2569 14:35:16

1) การเลื่อนขึ้นเงินเดือน และการออกจากราชการของตะโตะยะ
ยุติธรรม ให้รัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง เมื่อ ก.ต. เห็นชอบ และการโอนตะโตะยะยุติธรรมไปเป็น
ข้าราชการธุรการ ข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายอื่นให้รัฐมนตรีสั่งได้ เมื่อตะโตะยะ
ยุติธรรมผู้นั้นยินยอม และ ก.ต. เห็นชอบ¹

2) ให้ฝ่ายทนายผู้พิทักษ์ 6 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัยและการลงโทษมาใช้บังคับแก่ตะโตะยะยุติธรรม ส่วน
กรณีที่ตะโตะยะยุติธรรมถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก รัฐมนตรีหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาค ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทำการสอบสวนหรือสั่งพิจารณารายการ แล้วแต่กรณี²

ข) คุณสมบัติของตะโตะยะยุติธรรม อิสลามคำสันนิษฐานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตะโตะยะยุติธรรม ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการกำหนดไว้คือ

- 1) มีคุณสมบัติตามมาตรา 27 (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11)
- 2) อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
- 3) มีภูมิลำเนาในศาสนาอิสลามพอที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก และ
- 4) มีความรู้ภาษาไทยเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา³

เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของตะโตะยะยุติธรรม ในกรณีที่เป็นความรู้ในศาสนาอิสลาม
และความรู้ภาษาไทย ซึ่งเดิมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2497
มาตรา 36 กำหนดให้การบรรจุและแต่งตั้งตะโตะยะยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ซึ่งรัฐมนตรีกำหนด โดยคัดเลือกจากอิสลามคำสันนิษฐานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

¹ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521.

² มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521.

³ มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521.



มีความรู้ในคำสอนอิสลามพอที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม เกี่ยวกับครอบครัว
และมรดก

มีความรู้ภาษาไทยพออ่านออกเขียนได้

จะเห็นว่าคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น ยังไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของตะโต๊ะ
ยุติธรรมในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
และผลประโยชน์ของประชาชนมุสลิม การที่กฎหมายกำหนดคุณสมบัติของตะโต๊ะยุติธรรมไว้ว่า
เป็นแต่เพียงเป็นผู้มีความรู้ในคำสอนอิสลามพอที่จะเป็นผู้ชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวข้องด้วย
ครอบครัวมรดกนั้น เป็นการบัญญัติไว้กว้างเกินไป เพราะเป็นการยากแก่การตรวจสอบว่ามี
ความรู้ทางคำสอนอิสลามมากน้อยเพียงใด¹ จึงจะสามารถชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับ
ครอบครัวมรดก เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า กฎหมายอิสลามนั้นมีความซับซ้อนและมีความ
เห็นที่แตกต่างกันในแต่ละตำรา สิ่งน่าจะได้กำหนดให้แคบกว่าที่เป็นอยู่นี้ ซึ่งอาจจะกำหนดให้
มีคุณสมบัติหรือผ่านการอบรม หรือผ่านการสอบความรู้ทางกฎหมายอิสลามจากสถาบันทางคำสอน
อิสลาม เป็นต้นว่าสำนักจุฬาราชมนตรี หรือคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ในนามของ
ทางราชการ ซึ่งเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในศาลคำสอนอิสลามนี้ ประมวล
กฎหมายว่าด้วยสถานบุคคลมุสลิมฟิลิปปินส์ (Code of muslim personal laws of the
Philippines) ได้กำหนดคุณสมบัติสำหรับเรื่องที่เป็นความรู้เกี่ยวกับคำสอนอิสลามเอาไว้
คือต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ในหลักคำสอน (Sharia) และหลักกฎหมายอิสลาม (Islamic
Jurisprudence) จากศาลสูง และได้เป็นสมาชิกพิเศษของเนติบัณฑิตสภาฟิลิปปินส์ (Special
membership in The Phillippines Bar) แสดงให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ได้ให้ความสำคัญแก่
ความรู้ทางกฎหมายอิสลามสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาในศาลคำสอน

¹ วิชัย ลิขิตนันทน์, ตะโต๊ะยุติธรรม, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 361.

ส่วนคุณสมบัติอีกประการหนึ่ง คือความรู้ภาษาไทย ความรู้ภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาในศาล เพราะตะโต๊ะยุติธรรมต้องร่วมปรึกษาข้อกฎหมายอิสลามกับผู้พิพากษา หรือรับฟังคำพยานในการพิจารณาคดีอิสลาม นอกจากนั้นแล้วตะโต๊ะยุติธรรมก็ต้องจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในเรื่องกฎหมายอิสลามและเรื่องสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี เพราะถ้าหากขาดความรู้ในสิ่งเหล่านี้ อาจจะทำให้การพิจารณาคดีไม่ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ และอีกประการหนึ่ง ตะโต๊ะยุติธรรมเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีในนามของพระมหากษัตริย์ ควรจะต้องมีความรู้ภาษาไทย ซึ่งในบางครั้งตะโต๊ะยุติธรรมจะต้องทราบถึงระเบียบการต่าง ๆ ของทางราชการนอกเหนือจากกฎหมายอิสลาม หรืออาจจะเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาแก่มุสลิมในเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับทางราชการ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาไทยพอสมควรจึงจะศึกษาถึงระเบียบและวิธีปฏิบัติของทางราชการได้

จะเห็นว่าการที่ทางราชการกำหนดคุณสมบัติในเรื่องความรู้ภาษาไทย เกือบได้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา นั้น จึงเป็นการกำหนดความรู้ภาษาไทยไว้ต่ำเกินไป ไม่เหมาะสมกับสถานที่และหน้าที่ตะโต๊ะยุติธรรม ควรจะมีการยกระดับความรู้ภาษาไทยของตะโต๊ะยุติธรรม

สำหรับเรื่องคุณสมบัติของตะโต๊ะยุติธรรมได้เป็นปัญหาในการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม และได้มีข้อเสนอแนะจากการสัมมนาว่า สมควรยกระดับความรู้ภาษาไทยของตะโต๊ะยุติธรรมให้สูงขึ้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนคุณสมบัติอื่นเหมาะสมดีแล้ว ส่วนความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะจากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะจากการสัมมนาว่า ควรยกระดับความรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้นเกือบได้ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3 เดิม) แต่ไม่กระทบถึงสถานภาพของตะโต๊ะยุติธรรมที่อยู่ในตำแหน่งก่อนแล้ว ซึ่งในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนี้ จำเป็นต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะ ก็ควรมอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้¹

¹ การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามฯ, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 148.

จากความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาข้อ เสนอแนะจากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม แสดงว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องคุณสมบัติของตะเีตะยุติธรรม โดยได้พยายามที่จะยกระดับความรู้ภาษาไทยของตะเีตะยุติธรรมให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว¹

ข) วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งตะเีตะยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ การแต่งตั้งตะเีตะยุติธรรมไว้ 2 ฉบับคือ

- 1) ออกโดยอาศัยความตามมาตรา 36, 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2497 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - (ก) เมื่อถึงคราวที่จะต้องมีการบรรจุแต่งตั้งตะเีตะยุติธรรม ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลประกาศรับสมัครอิสลามคำลั่นกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่งระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2497 เพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งตะเีตะยุติธรรม
 - (ข) เมื่อพ้นกำหนดเวลารับสมัครแล้ว ให้อธิบดีผู้พิพากษาจัดทำบัญชีผู้สมัครซึ่งสมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นตะเีตะยุติธรรมขึ้น โดยปรึกษากับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

(ค) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นสมควรบรรจุผู้สมัครผู้ใดเป็นตะเีตะยุติธรรม จะได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นตะเีตะยุติธรรม

- 2) ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 44 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

¹ กรรมการบางท่านของคณะกรรมการพิจารณาข้อ เสนอแนะจากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม เห็นว่าควรเน้นคุณสมบัติในทางหลักคำสอนให้มากกว่าที่จะไปเพิ่มคุณสมบัติภาษาไทย ไม่ควรเน้นคุณวุฒิภาษาไทย เพราะงานของตะเีตะยุติธรรมก็อยู่ที่การใช้กฎหมายอิสลามไม่ใช่ภาษาไทย

(ก) เมื่อถึงคราวที่จะต้องมีการบรรจุและแต่งตั้งตะโตะยุดิธรรม ให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคประกาศรับสมัครอิสลามคำสันนิษฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นตะโตะยุดิธรรม

(ข) เมื่อพ้นกำหนดเวลารับสมัครแล้ว ให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคจัดทำบัญชีผู้สมัคร ซึ่งสมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นตะโตะยุดิธรรม โดยปรึกษากับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

(ค) เมื่อคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นสมควรบรรจุผู้สมัครผู้ใดเป็นตะโตะยุดิธรรม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สมัครนั้นเป็นตะโตะยุดิธรรม โดยความเห็นชอบของ ก.ต.

ปรากฏว่าวิธีการแต่งตั้งตะโตะยุดิธรรมตามวิธีการที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดไว้ดังกล่าวมาแล้ว ไม่ได้ได้รับการยอมรับจากอิสลามคำสันนิษฐานแต่ประการใด และอิสลามคำสันนิษฐานเคยรวมกันคัดค้านตะโตะยุดิธรรมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งด้วยวิธีการดังกล่าวมาแล้ว ปัจจุบันนี้ ในทางปฏิบัติจึงใช้วิธีการแต่งตั้งจากบุคคลที่โตะยุดิฮัมมาในแต่ละจังหวัดลงคะแนนเลือกตั้งขึ้น กล่าวคือ เมื่อตะโตะยุดิธรรมในจังหวัดใดว่างลง กระทรวงยุติธรรมโดยอธิบดีผู้พิพากษาภาคจะประกาศรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครสมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นตะโตะยุดิธรรมแล้ว ก็จะกำหนดวันให้โตะยุดิฮัมมาในจังหวัดนั้นมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตะโตะยุดิธรรม¹

เหตุที่โตะยุดิฮัมมาเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งตะโตะยุดิธรรมนั้น ตามหลักคำสอนอิสลามสำหรับประเทศที่มีเจ้าผู้ครองนครเป็นอิสลามคำสันนิษฐาน เจ้าผู้ครองนครเป็นผู้แต่งตั้งตำแหน่งตุลาการนี้เอง แต่ในประเทศที่ไม่มีเจ้าผู้ครองนครดังกล่าว เช่นประเทศไทยก็อนุโลมให้

¹ วิชาญ ลิมาพนนท์, ตะโตะยุดิธรรม, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, อ่างแล้ว, หน้า 362.

โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้เลือกตั้ง เพราะถือว่าโต๊ะอิหม่ามเป็นผู้นำของชาวมุสลิม และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา ผู้ที่จะเป็นโต๊ะอิหม่ามได้ต้องได้รับการคัดเลือกจากอิสลามคำสนิกแห่งมัสยิดนั้น ๆ โต๊ะอิหม่ามจึงเท่ากับเป็นตัวแทนหรือเสียงของชาวมุสลิมทั้งหมด การเลือกตั้งโต๊ะอิหม่ามที่จังหวัดลพบุรีตามสารตรากระทรวงยุติธรรมที่ 30/4353 ปรากฏหลักฐานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเชิญโต๊ะอิหม่ามมาออกเสียง และผู้ใดคะแนนนิยมก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโต๊ะอิหม่ามด้วยเหตุนี้ การเลือกตั้งโต๊ะอิหม่ามจึงถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมา¹

วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งโต๊ะอิหม่าม โดยให้โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้คัดเลือกนั้น ได้มีผู้แสดงความเห็นว่าเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เพราะปรากฏว่าผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโต๊ะอิหม่ามได้ใช้วิธีการออกไปหาเสียงจากโต๊ะอิหม่าม ซึ่งวิธีการเช่นนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเป็นโต๊ะอิหม่ามก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระได้ เพราะย่อมจะมีความเกรงอกเกรงใจ รู้สึกสำนึกในบุญคุณของโต๊ะอิหม่ามที่เคยช่วยเหลือ เคยลงคะแนนเลือกตั้งตนมาตลอด เป็นวิธีการที่ไม่สามารถคัดเลือกโต๊ะอิหม่ามที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะผู้ที่มีความรู้สูงถึงขั้นได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายอิสลามจากต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย มักจะไม่กว้างขวางในหมู่โต๊ะอิหม่าม จากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่าวิธีการคัดเลือกโต๊ะอิหม่ามนั้น ควรจะมีการลอบคัดเลือกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะอิสลามประจำจังหวัด หรือจัดตั้งคณะกรรมการไปจากส่วนกลางเพื่อทำการลอบคัดเลือก โดยทำการลอบรายลักษณะวิชา เช่นกฎหมายอิสลาม ความรู้ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน สังคมศึกษา เป็นต้น²

จากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรจะให้มีการทดสอบภูมิรู้คำสนาอิสลามของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นโต๊ะอิหม่ามเสียก่อนว่า จะสามารถวินิจฉัยชี้ขาดกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวมรดกได้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงให้โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่ผ่านการทดสอบนั้น เลื่อนให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการแต่งตั้งเป็นโต๊ะอิหม่ามต่อไป

¹ พินิจ จักรางกูร, กฎหมายอิสลาม, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามฯ, อ่างแก้ว, หน้า 315.

² วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์, โต๊ะอิหม่าม, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามฯ, อ่างแก้ว, หน้า 362-363.

ซึ่งการกระทำดังกล่าว จะเป็นการถูกต้องตามหลักคำสอนด้วย เพราะตะโตะยุติธรรมนั้นมียอำนาจที่จะรับทำการล้มล้างได้ด้วย นอกเหนือจากการวินิจฉัยชี้ขาด จึงมีข้อเสนอแนะว่า การแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 ให้มีการระบุอย่างชัดเจนว่า ในการบรรจุแต่งตั้งตะโตะยุติธรรมนั้น จะต้องมีการทดสอบภูมิรู้คำสอนอิสลามของผู้สมัครก่อน แล้วจึงให้ตะโตะอิหม่ามคัดเลือกบุคคลที่ผ่านการทดสอบนี้ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งต่อไป¹

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะจากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามเห็นชอบด้วยต่อข้อเสนอแนะจากการสัมมนาฯ ว่าควรแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้มีการระบุอย่างชัดเจนว่า จะต้องมีการทดสอบภูมิรู้ทางคำสอนอิสลามของผู้สมัครก่อน โดยให้ตั้งคณะกรรมการทดสอบขึ้นเฉพาะการบรรจุแต่งตั้งเป็นคราว ๆ ไป ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนี้ จำต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอ ก็ควรมอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการ²

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าทุกฝ่ายจะเห็นพ้องกันว่า ควรจะมีการทดสอบความรู้ของผู้สมัครเป็นตะโตะยุติธรรม แต่ก็ต้องให้ตะโตะอิหม่ามเข้ามามีส่วนในการคัดเลือกตะโตะยุติธรรมอยู่ดี เนื่องจากเหตุผลทางคำสอนอิสลามดังที่กล่าวมาแล้ว และยังเป็นวิธีการที่เคยปฏิบัติมาช้านาน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องคำนึงถึงวิธีการคัดเลือกที่จะทำให้ได้ตะโตะยุติธรรมที่มีความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมกับผู้พิพากษาคำล่ำ ๆ ไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้กฎหมายอิสลามในอนาคต เพราะถ้าหากว่าตะโตะยุติธรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมผู้พิพากษาแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามก็อาจถือเป็นบรรทัดฐานต่อไปได้ จะทำให้ภาพพจน์ของตะโตะยุติธรรมโดดเด่น เป็นที่น่าเชื่อถือจากทางการ ทั้งทาง

¹ การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม, อ้างแล้ว, หน้า 139.

² การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม, กระทรวงยุติธรรม 2525, หน้า 149 (หนังสือกระทรวงยุติธรรมที่ ยร 0401/25946 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2525)

รัฐบาลและเอกชน ซึ่งอาจเป็นผลให้รัฐบาลต้องมีการปรับปรุงแก้ไขลักษณะและขอบเขตการใช้อิฎหมายอิสลามให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม เช่น อาจจะมีการก่อตั้งศาลศาสนาเพื่อพิจารณาคดีครอบครัวให้เป็นเอกเทศต่างหากจากศาลแพ่ง เช่นเดียวกับต่างประเทศก็ได้ ซึ่งสมควรที่สถาบันทางศาสนาอิสลามพึงจะให้ความสำคัญต่อวิธีการลอบคัดเลือกตะเฎะยุติธรรม

ค) วิธีพิจารณาคดีครอบครัวมรดกอิสลาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้อิฎหมายอิสลามฯ ได้กำหนดวิธีพิจารณาคดีครอบครัวมรดกอิสลามเอาไว้ดังนี้

- 1) การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นดังกล่าว ต้องมีตะเฎะยุติธรรม 1 นาย นั่งพิจารณาคดีพร้อมด้วยผู้พิพากษาชั้นต้น
- 2) ตะเฎะยุติธรรมมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาด้วย คำวินิจฉัยของตะเฎะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามเป็นอันเด็ดขาด
- 3) ตะเฎะยุติธรรมอาจถูกคัดค้านมิให้นั่งพิจารณาได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษา
- 4) เมื่อตะเฎะยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้คู่ความตกลงกันเลือกอิสลามคำสันนิษฐาน 1 นาย ปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะคดี ถ้าตกลงกันไม่ได้ต่างเสนอชื่ออิสลามคำสันนิษฐานที่สมควรต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฝ่ายละเท่ากัน แต่ไม่ให้เกินฝ่ายละ 3 นาย เมื่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเลือกผู้ใดจากรายชื่อที่คู่ความเสนอ ให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นตะเฎะยุติธรรมเฉพาะคดีนั้นได้

การดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีครอบครัวมรดกของอิสลามพอสรุปดังนี้

1. ในการพิจารณาคดีทุกครั้งในศาลชั้นต้นของจังหวัดทั้ง 4 ต้องมีตะเฎะยุติธรรม 1 นาย นั่งพิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษา สำหรับองค์คณะของผู้พิพากษาต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23 คือต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 นายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา เพราะเป็นคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก¹ ถ้าหากการพิจารณาคดีดังกล่าว

¹

พิพัฒน์ จักรางกูร, การสมมนาการใช้อิฎหมายอิสลามฯ, อ้างแล้ว, หน้า 34.

ไม่มีตะโตะยุติธรรมนั่งร่วมการพิจารณานั้น ก็ไม่ชอบตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1349/2494 นางคอดีเยาะ เจ้าเลาะ โจทก์ นางแม่ปะปีโก ตือราแม จำเลย คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท โดยอ้างว่าเป็นของโจทก์กับเรียกค่าเสียหายที่จำเลยทำละเมิด จำเลยต่อสู้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ทางพิจารณาได้ความว่าทรัพย์สินที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับสามี สามีโจทก์ตายจึงตกเป็นมรดกแก่โจทก์กับบุตรของโจทก์ซึ่งเป็นสามีจำเลย บุตรของโจทก์ถึงแก่กรรม จำเลยจึงได้รับมรดกส่วนของบุตรโจทก์ด้วย ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ จำเลยต่างนับถือศาสนาอิสลาม และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี จึงใช้กฎหมายอิสลามบังคับ แต่คดีนี้ตะโตะยุติธรรมไม่ได้พิจารณาด้วย จึงจะพิจารณาพิพากษาไม่ได้ ให้ยกฟ้องในข้อนี้ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความที่จะว่ากล่าวกันใหม่ภายในอายุความ โจทก์ จำเลยต่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปความ โจทก์จำเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้โจทก์จำเลยต่างนับถือศาสนาอิสลาม และต้องวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดก ซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ พ.ศ. 2489 ให้ใช้กฎหมายอิสลามบังคับ และในศาลชั้นต้นให้ตะโตะยุติธรรมนั่งพิจารณาพร้อมกับผู้พิพากษา แต่คดีนี้มิได้ปฏิบัติเช่นนั้น จึงเห็นฟ้องด้วยกับศาลอุทธรณ์ที่ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ ไม่จำเป็นต้องยกฟ้อง โดยให้ไปฟ้องใหม่ตั้งคำพิพากษาศาลชั้นต้น

2. ตะโตะยุติธรรมมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเฉพาะข้อกฎหมายอิสลามเท่านั้น ส่วนปัญหาข้อเท็จจริง หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นเป็นอำนาจของผู้พิพากษา

คำวินิจฉัยชี้ขาดของตะโตะยุติธรรมรวมอยู่ในคำพิพากษา โดยปกติผู้พิพากษาเป็นผู้จดคำพยานและเรียงคำพิพากษา เมื่อเสร็จสำนวนก็ทำคำพิพากษาอย่างคดีแพ่งธรรมดา โดยมีตะโตะยุติธรรมลงลายมือชื่อในคำพิพากษาด้วย¹ แต่ถ้าคดีมีประเด็นข้อพิพาททั้งที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายอิสลามและที่ไม่ใช่ข้อกฎหมายอิสลามปะปนกัน หากศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่มีตะโตะยุติธรรมร่วมและวินิจฉัยลงข้อด้วย การพิจารณาพิพากษานั้นก็ไม่ชอบเฉพาะข้อพิพาทที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกเท่านั้น ส่วนการพิจารณาพิพากษาคดีในประเด็นข้ออื่น

¹ พัทธน์ จักรางกูร, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามฯ, อ้างแล้ว, หน้า 311.

ไม่ได้อยู่ในบังคับที่ต้องมีตะโต๊ะยุติธรรมร่วมด้วย แม้ตะโต๊ะยุติธรรมจะมีได้ร่วมพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาด้วย ก็ไม่ทำให้กระบวนการพิจารณาและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในข้อนี้เสียไป (คำพิพากษาฎีกาที่ 1029 ถึง 1030/2511 นางลีเยาะ บินหะมะ นางวาแม บินเล๊ะมะ โจทก์ นางยา บินฮาเซาะจำเลย)

3. คำฟ้องหรือคำร้อง จะต้องบรรยายให้ปรากฏว่าคู่ความเจ้ามรดกหรือผู้ร้องขอเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม และคดีที่ฟ้องหรือร้องขอนั้นเกี่ยวข้องกับครอบครัวมรดก ซึ่งต้องบังคับตามกฎหมายอิสลามเมื่อพนักงานรับฟ้องตรวจฟ้องแล้วก็ให้ตะโต๊ะยุติธรรมตรวจฟ้องอีกครั้ง ถ้าเห็นว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามแล้ว ตะโต๊ะยุติธรรมก็บันทึกที่คำฟ้องหรือคำร้องขอว่า "ได้ตรวจแล้ว" ต่อไปพนักงานรับฟ้องจะหมายเหตุรับฟ้องว่า "ความศาสนา" แล้วนำเสนอสื่อพิพากษาสั่งคำฟ้องหรือร้องขอต่อไป¹

อนึ่ง ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นนั้น กฎหมายอิสลามที่ใช้บังคับนี้ไม่ใช่กฎหมายต่างประเทศ ฉะนั้น ในการพิจารณาคดีซึ่งต้องใช้กฎหมายอิสลามก็เป็นหน้าที่ของตะโต๊ะยุติธรรมที่นั่งพิจารณาเป็นผู้นำกฎหมายอิสลามมาบังคับคดี หากไม่ใช่หน้าที่ของคู่ความจะนำสืบไม่ ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาลรับรู้เอง (คำพิพากษาฎีกาที่ 1355/2479 นายตนกูอาหมัด บินตัมมะหงง โจทก์ คุณหญิงหวันเต๊ะ ภูมินาถกักดักกับพวก จำเลย)

สำหรับวิธีพิจารณาคดีนอกเหนือจากบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น มีปัญหาว่าจะใช้กฎหมายอิสลามแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยหรือไม่ โดยสืบเนื่องจาก มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ให้ใช้ในการ "วินิจฉัยชี้ขาดคดี" เท่านั้น และยังกำหนดให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนพระราชบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั้น ไม่ได้ระบุว่าให้ใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ข้อ 32 ว่า ให้ใช้กฎหมายอิสลามในการ "พิจารณาคำพิพากษาคดี" ศาลจึงสามารถนำเอากฎหมายอิสลามมาบังคับแทน

¹ พัทธน์ จักรางกูร, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามฯ, อ้างแล้ว, หน้า 311.



บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้¹

จากปัญหาดังกล่าวมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายหนึ่งเห็นว่ากฎหมายอิสลามใช้บังคับได้เฉพาะทางสารบัญญัติเท่านั้น ส่วนวิธีสบัญญัติต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเช่นเดียวกับคดีแพ่งอื่น โดยให้เหตุผลว่ากฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมืองนั้นได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ใช้กฎหมายอิสลามในการพิจารณาพิพากษา แต่ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม ได้กำหนดว่าให้ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้น และยังได้กำหนดให้ว่าเอกกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั้น ไม่ได้ระบุว่าให้ใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามออกใช้ภายหลังพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477 ถ้าจะให้ใช้กฎหมายอิสลามแทนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่ง ก็น่าจะเขียนไว้อย่างชัดเจน²

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ในการพิจารณาคดีดังกล่าวต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกไว้โดยเฉพาะก็ต้องบังคับตามกฎหมายอิสลาม³

จากความเห็นทั้งสองฝ่าย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ความเห็นที่ว่าในการพิจารณาคดีต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เฉพาะกรณีที่กฎหมายอิสลามไม่มีข้อบัญญัติเหล่านั้นเอาไว้ น่าจะเป็นความเห็นที่จะได้รับการพิจารณา กล่าวคือ

¹ ลุย หงส์ไกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 เล่ม 1, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520, หน้า 3.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 321.

³ อุทากร พันธุลาภ, ตะต๊ะยุติธรรม, การสมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 329.

1. กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนั้น มีบทบัญญัติที่คาบเกี่ยวกันทั้งที่เป็นสารบัญญัติและวิธีบัญญัติ¹ เป็นต้นว่า การนำสืบพยาน การรับฟังพยาน คุณสมบัติของพยาน พยานที่ศาลจะรับฟังไม่ได้ตามหลักกฎหมายอิสลามที่ใช้เป็นคู่เมื่อในศาล² ฉะนั้น การพิจารณาคดีจะแยกไปว่าเป็นสารบัญญัติหรือวิธีบัญญัติ โดยถือว่าถ้าส่วนใดเป็นสารบัญญัติก็ใช้กฎหมายอิสลามบังคับได้ ส่วนใดเป็นวิธีบัญญัติก็ใช้กฎหมายอิสลามบังคับไม่ได้ ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแทน หากเป็นเช่นนั้นก็ย่อมเป็นการไม่สะดวกในการพิจารณา ซึ่งอาจเป็นผลให้คำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลฎีกาความเหมาะสม ซึ่งต่อไปจะทำให้ประชาชนมุสลิมขาดความเชื่อถือในคำพิพากษาของศาล

2. เมื่อพิจารณาตามมาตรา 1 ของคำแปลหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ซึ่งแปลเสร็จในปี พ.ศ. 2484 เขียนไว้ว่า เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งหลักกฎหมายนี้ที่จะบังคับใช้ ให้มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญา มาใช้แทนที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายนี้

การที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ พ.ศ. 2489 ซึ่งประกาศใช้หลังคำแปลหลักกฎหมายอิสลาม มิได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ให้มีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้ได้ เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่บทบัญญัติของกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกกำหนดเอาไว้เฉพาะ คงจะได้พิจารณาถึงบทกฎหมายตามคำแปลหลักกฎหมายอิสลามดังกล่าว และการที่กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ได้กำหนดให้ใช้กฎหมายอิสลามในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็อาจเนื่องมาจากในขณะนั้นยังร่างคำแปลหลักกฎหมายอิสลามดังกล่าวยังไม่เสร็จจึงต้องกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน

¹ พินิจ จักรางกูร, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม, อ้างแล้ว, หน้า 321.

² ดูคำแปลหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก มาตรา 11, 12, 13, 14, 16, 18 และ 19.

3. พิจารณาจาก มาตรา 3¹ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งยกเว้นไม่ให้นำเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับในกรณีนี้

คำลที่มีข้อบังคับสำหรับคำลนั้นโดยเฉพาะ

คำลที่มีกฎหมายให้ใช้ธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายในทางคำลนั้น

ถ้าหากจะพิจารณาบทกฎหมายดังกล่าวที่ให้นำเอากฎหมายในทางคำลนั้นมาใช้บังคับ แทนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งในขณะนั้นก็มีแต่คำลที่มีกฎหมายให้ใช้ธรรมเนียมประเพณีอิสลามเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ถ้าหากมีกฎหมายให้นำเอากฎหมายประเพณีหรือกฎหมายในทางคำลนั้นมาใช้บังคับแล้วก็ไม่ได้นำเอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ เพราะผู้ร่างกฎหมายอาจเห็นว่าธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายในทางคำลนั้นไม่มีการแบ่งแยกเป็นกฎหมายสำหรับบัญญัติหรือวิธีบัญญัติ ฉะนั้น เมื่อกฎหมายให้นำเอาธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายในทางคำลนั้นมาใช้บังคับแล้ว ก็ได้นำเอาธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมายในทางคำลนั้นในส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติและสำหรับบัญญัติมาใช้โดยไม่มีการแยกว่า เฉพาะที่เป็นกฎหมายสำหรับบัญญัติเท่านั้นที่จะใช้บังคับได้

4. เจตนารมณ์ในการใช้กฎหมายอิสลาม เมื่อพิจารณาถึงนโยบายในการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามก็เพื่อจะทบทวนให้ชนชาวอิสลามใน 4 จังหวัด ให้บำเพ็ญสิทธิคำลอิสลามอันเป็นที่เคารพสักการะของชนชาวอิสลามโดยสมบูรณ์² การตีความ

¹ มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามที่ได้อตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2478 เป็นต้นไป

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้ในคำลทั่วไปตลอดราชอาณาจักร ยกเว้นแต่ในคำลพิเศษที่มีข้อบังคับสำหรับคำลนั้น และมีกฎหมายให้ใช้ธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายในทางคำลนั้น ในคำลใด ให้คำลนั้นยกธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายนั้น ๆ มาใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เว้นแต่ข้อความจะได้ตกลงกันให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ ฯลฯ

² การร พันธ์ลาก, ตะตะยะยุติธรรม, การล้มเลิกการใช้กฎหมายอิสลามฯ, อ้างแล้ว

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายอิสลามก็ควรคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการใช้กฎหมายอิสลามมากกว่าที่จะยึดถือตามตัวอักษร เพราะถ้าหากยึดถือตามตัวอักษรแล้ว การใช้กฎหมายอิสลามก็ไม่อาจจะเป็นไปได้เพื่อสนองเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ การที่จะวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามได้อย่างถูกต้อง หลักทางศาสนา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการพิจารณาไปตามที่กฎหมายอิสลามกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะ ถ้าหากไม่ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายอิสลามอาจทำให้คำวินิจฉัยนั้นไม่สมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลาม

ง) การอุทธรณ์ฎีกาคดีครอบครัวมรดกอิสลาม ตามมาตรา 4 วรรคสุดท้าย แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามบัญญัติว่า คำวินิจฉัยของตะต๊ะยุติธรรมในกฎหมายอิสลามให้เป็นอันเด็ดขาด ซึ่งจะอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้นั้น หมายความว่าถึงเฉพาะคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามเท่านั้น แต่ถ้าคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาในปัญหาข้ออื่น และปัญหาข้ออื่นนั้น ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น เช่นศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินที่พิพาทเป็นของโจทก์ แต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นของจำเลย หรือประการอื่นเช่นนี้ เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่ โดยถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาวินิจฉัยเช่นนี้ ศาลชั้นต้นจะต้องพิจารณาใหม่ร่วมกับตะต๊ะยุติธรรมตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาวินิจฉัยตามคำพิพากษาฎีกาที่ 232/2493 นายอาแว บาลงหรืออาแว ลาลอกะนิ โจทก์ นายอาแวเวาะและมะเฮ็ง จำเลย¹

การ การอุทธรณ์ฎีกาสําหรับคดีครอบครัวมรดกอิสลามนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกตะต๊ะยุติธรรมแล้ว ยิ่งควรจะให้มีการอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของตะต๊ะยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับพิพากษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกแต่งตั้งอย่างเข้มงวดกับต้องให้มีการอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาได้ แต่อย่างไรก็ตาม การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นควรจะเป็นการอุทธรณ์เพียงชั้นเดียว คืออาจจะอุทธรณ์หรือฎีกาข้ามชั้นไปยังศาลฎีกาเลย และถือว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาถึงที่สุด เช่นเดียวกับการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลศาสนาในสิงคโปร์ ที่อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์

1

พิพัฒน์ สักราญกูร, กฎหมายอิสลาม, การสมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม, อ้างแล้ว หน้า 322.

และคำตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือว่าเป็นที่สุด ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์นั้น สามารถอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาลศาลาได้ เช่นเดียวกับคำพิพากษาของศาลทั่ว ๆ ไป ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์

การอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของตะโต๊ะยุติธรรมอาจมีปัญหาติดตามมา ว่าลัถาบันทางศาลาอิสลามใดจะเป็นผู้พิจารณาคดีอุทธรณ์ฎีกา เนื่องจากขณะนี้เพียงศาลชั้นต้นโดยตะโต๊ะยุติธรรมเพียงลัถาบันเดียวเท่านั้นที่มีหน้าที่ในการบริหารกฎหมายอิสลาม ถ้าหากมีการอุทธรณ์ฎีกาคำตัดสินของตะโต๊ะยุติธรรมขึ้นไปสู่ศาลสูงแล้ว คำตัดสินของผู้พิพากษาในศาลสูงก็อาจเป็นคำตัดสินของผู้ที่ไม่มีอำนาจตัดสินตามกฎหมายอิสลามได้ และจากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามฯ มีข้อเสนอแนะจากการสัมมนาฯ ว่าควรแก้ไขกฎหมายให้สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาคำวินิจฉัยชี้ขาดของตะโต๊ะยุติธรรมได้ โดยทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และจุฬาราชมนตรีพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาในข้อกำหนดอิสลามได้ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะจากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามก็เห็นว่า ควรแก้ไขกฎหมายให้สามารถอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของตะโต๊ะยุติธรรมได้ หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยก็ควรมอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้พิจารณาขั้นตอน และวิธีการอุทธรณ์ฎีการ่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและจุฬาราชมนตรี¹

คณะกรรมการอิสลาม

นอกจากศาลาอิสลามที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกำหนดอิสลามแล้ว ยังมีคณะกรรมการอิสลามที่เป็นลัถาบันทางศาลาอิสลามลัถาบันหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญต่อการบริหารกฎหมายอิสลามในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารกฎหมายอิสลาม หรือให้คำปรึกษากฎหมายอิสลามแก่บุคคลทั่ว ๆ ไป หรือแก่ทางราชการหรือใกล้เคียงข้อพิพาทของมุสลิม ดังรายละเอียดที่จะได้ศึกษาต่อไปนี้

¹ การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามฯ, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 147.

ก. คณะกรรมการอิสลามของสิงคโปร์ ตามพระราชบัญญัติ Administration of muslim law Act ได้มีคณะกรรมการอิสลามเรียกว่า Majlis UgamaIslam Singapura ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดีสิงคโปร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามในสิงคโปร์¹

คณะกรรมการอิสลาม Majlis UgamaIslam มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่สามารถที่จะทำการฟ้องคดีหรือถูกฟ้องในนามของคณะกรรมการหรืออื่น ๆ ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลตลอดจนเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตาย หรือทรัพย์สินของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้²

1. สมาชิกคณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประกอบด้วย

- ก) ประธานกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสิงคโปร์
- ข) มุฟตี (Mufti)
- ค) สมาชิกไม่เกิน 5 คน ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดยคำแนะนำ

ของรัฐมนตรี

ง) สมาชิกไม่น้อยกว่า 7 คนที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีจากรายชื่อ

ที่ประธานคณะกรรมการอิสลามเสนอตามปกติ นอกจากมุฟตีแล้วสมาชิกของคณะกรรมการจะดำรงตำแหน่งไปจนครบวาระ 3 ปี และสมาชิกคณะกรรมการอาจจะถูกแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ นอกจากนั้นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการอิสลามจะต้องเป็นพลเมืองของสิงคโปร์ มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และเป็นมุสลิม³

สมาชิกคณะกรรมการอิสลามถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (Public Servant) ตามความมุ่งหมายของกฎหมายอาญา⁴

¹ มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

² มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์ -

³ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

⁴ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

2. เลขานุการคณะกรรมการอิสลาม กฎหมายได้กำหนดให้มีเลขานุการของคณะกรรมการอิสลามเอาไว้ คือผู้ที่จะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการอิสลามจะต้องเป็นข้าราชการมุสลิม (Muslim public officer) และได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรี

เลขานุการคณะกรรมการอิสลามมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง แต่ไม่มีสิทธิที่จะออกเสียง¹

3. การแต่งตั้งมุฟตี (Mufti) ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการอิสลามแล้วประธานาธิบดีสิงคโปร์ต้องแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นมุฟตี มุฟตีต้องเป็นสมาชิกโดยตำแหน่งของคณะกรรมการอิสลาม²

4. คณะกรรมการกฎหมาย (Legal Committee) ภายในคณะกรรมการอิสลาม มีคณะกรรมการหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกฎหมาย (Legal Committee) ซึ่งประกอบด้วยมุฟตี

สมาชิกของคณะกรรมการอิสลาม 2 คน

บุคคลที่เป็นมุสลิมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการอิสลามไม่เกิน 2 คน

สมาชิกของคณะกรรมการกฎหมาย นอกจากมุฟตีต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสิงคโปร์โดยการแนะนำของคณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการกฎหมายมีมุฟตี เป็นประธาน ในกรณีที่มุฟตีไม่อยู่ ประธานาธิบดีของสิงคโปร์โดยความเห็นของคณะกรรมการอิสลามจะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดทำหน้าที่เป็นประธาน สำหรับองค์ประชุมของคณะกรรมการกฎหมายนั้นต้องประกอบด้วยประธานและสมาชิก 2 นาย โดยต้องเป็นสมาชิกที่มาจากคณะกรรมการอิสลาม 1 นาย ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการกฎหมายสามารถที่จะกำหนดวิธีพิจารณาขึ้นเอง และสมาชิกทุกคนถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา³

¹ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

² มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

³ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฎหมายคือ

ก) วินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลาม (Ruling) หรือ Fetua คณะกรรมการกฎหมายมีหน้าที่ที่จะให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายอิสลามแก่ผู้ร้องขอตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ

1) ทุกคนสามารถที่จะทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามร้องขอให้คณะกรรมการอิสลามวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลาม เมื่อเลขาธิการได้รับคำร้องขอจะต้องส่งหนังสือนั้นไปยังประธานคณะกรรมการกฎหมายโดยทันที

2) คณะกรรมการกฎหมายจะต้องพิจารณาทุก ๆ คำร้อง เว้นแต่เห็นว่าปัญหาที่ส่งมานั้นไม่มีสาระ (Frivellous) หรือคณะกรรมการกฎหมายมีเหตุผลอื่นที่ดีก็อาจจะไม่ตอบปัญหาที่ส่งมานั้นได้ นอกจากนั้นคณะกรรมการกฎหมายต้องทำการพิจารณาเพื่อทำคำวินิจฉัย ถ้าการวินิจฉัยนั้นได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเป็นเอกฉันท์ ประธานคณะกรรมการกฎหมาย ในนามของคณะกรรมการอิสลามต้องนำส่งคำวินิจฉัยตามนั้นโดยทันที แต่ถ้าในกรณีที่คณะกรรมการกฎหมายไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์จะต้องส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการอิสลาม การวินิจฉัยนั้นต้องถือตามเสียงข้างมาก

3) ถ้าบางคำ¹ ที่มีปัญหาข้อกฎหมายอิสลามในการตัดสินคดี คำสนั้นอาจขอความเห็นของคณะกรรมการอิสลามในบางปัญหา ปัญหานั้นต้องส่งไปที่คณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการกฎหมายในนามของคณะกรรมการอิสลามจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนั้นโดยถือเอาเสียงข้างมากและรับรองความเห็นไปยังคำลที่ขอความเห็นมา²

ข) อำนาจที่ติดตามมาของคณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการอิสลามและคณะกรรมการกฎหมายที่จะออกคำวินิจฉัยใด ๆ ต้องถือตามคำสอนของสำนักกฎหมายฮาฟาอี แต่ถ้าหากคณะกรรมการอิสลามและคณะกรรมการกฎหมายเห็นว่า คำสอนนั้นมีลักษณะที่ยึดต่อ

¹ คำสนั้นหมายความว่าคำลทั่ว ๆ ไป และคำลคำสนาตามมาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

² มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

ผลประโยชน์สาธารณะแล้ว คณะกรรมการดังกล่าวเมื่อได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็สามารถ
ถือตามกฎหมายอิสลามตามแนวความคิดของสำนักกฎหมายอื่นได้ แต่ต้องแสดงรายละเอียด
พร้อมกับคำอธิบายที่จำเป็นทั้งหมด

5. การทบทวนสำนวนคดี (Revision) คณะกรรมการอิสลามนอกจากจะมี
อำนาจหน้าที่ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ที่จะพิจารณาทบทวนสำนวนการพิจารณาของศาล
คำสนา หรือการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ ดังนี้คือ

ก) ประธานาธิบดีสิงคโปร์ โดยดุลพินิจนั้นสามารถที่จะเรียกสำนวนการ
พิจารณาที่ได้พิจารณาต่อหน้าศาล นายทะเบียน Kathi หรือ Naib Kathi แล้วส่งสำนวนให้แก่
คณะกรรมการอิสลามพิจารณา

ข) คณะกรรมการอิสลามภายหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วต้องให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาล นายทะเบียน Kathi หรือ Naib Kathi นั้นว่าต้องกลับคำวินิจฉัย
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมคำวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และประธานาธิบดีสิงคโปร์ต้องมี
คำสั่งตามคำแนะนำของคณะกรรมการอิสลาม

ค) คำวินิจฉัยที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้นถือว่า การกระทำ
ทั้งหมดของศาล นายทะเบียน Kathi หรือ Naib Kathi ก่อนหน้านั้นถูกต้องตามกฎหมาย¹

จากการศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามนั้น จะเห็นว่า คณะกรรมการ
อิสลามมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารกฎหมายอิสลามในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลสถาบันทาง
ศาสนาอื่น ๆ

ข. คณะกรรมการอิสลามของฟิลิปปินส์ ประมวลกฎหมายสถานบุคคลมุสลิม (Code
of Muslim Personal Law) ได้กำหนดให้คณะกรรมการอิสลามชั้น 2 คณะ เพื่อทำหน้าที่
ในการบริหารกฎหมายอิสลาม คือคณะกรรมการใกล้เคียงข้อพิพาทกับที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม

1

มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์



1. คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Agama Arbitration) คณะกรรมการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหมายถึงองค์ที่ประกอบด้วยประธานและตัวแทนของแต่ละฝ่ายประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการที่กระทำตามขั้นตอนเพื่อประนีประนอมข้อพิพาทของคู่กรณี¹ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหน้าที่ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอยู่ 3 กรณีคือ

ก) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการหย่า โดยการตอละ Ta lag หรือ Tafwid โดยมีวิธีดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทดังนี้

1) ข่ายมุสลิมผู้ใดได้กล่าวตอละ² ต้องทำหนังสือบอกกล่าวโดยมิชักช้ากับเลขานุการศาลศาสนาอิสลามประจำท้องถิ่น (Shariah Circuit Court) ที่ครอบครัวยุของเขาดำเนินอยู่ หนังสือบอกกล่าวนั้นต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หลังจากนั้นศาลต้องส่งสำเนาหนังสือนั้นให้แก่ภรรยาที่เกี่ยวข้อง คำกล่าวตอละนั้นจะยกเลิกไม่ได้ จนกระทั่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอีดาอ (Idda)³ หนังสือที่เสนอนั้นต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการกล่าวตอละแล้ว

2) ภายใน 7 วัน หลังจากรับหนังสือเลขานุการศาล ศาลต้องเรียกคู่กรณีแต่ละฝ่ายมาเพื่อเล่นอรายชื่อผู้แทน โดยศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งร่วมกับเลขานุการศาลในฐานะที่เป็นประธานขึ้นเป็นคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเล่นอรายงานต่อศาลถึงผลการไกล่เกลี่ย โดยอยู่บนพื้นฐานตามที่ได้ยอมรับกัน ศาลจะต้องทำคำวินิจฉัยไปตามผลของการไกล่เกลี่ย

3) บทบัญญัติตามที่ได้อ้างมาแล้วข้างต้นสามารถนำมาปฏิบัติในกรณีที่ภรรยาทำการ Tafwid⁴

¹ มาตรา 7 (A) แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลของฟิลิปปินส์

² ตอละ คือการคลายนิติสัมพันธ์สมรสของสามีอันขาดการสมรสจากภริยาโดยวิธีตอละ (มาตรา 82 ของคำแปลหลักกฎหมายอิสลาม)

³ อีดาอ คือกำหนดระยะเวลาซึ่งฝ่ายหญิงต้องห้ามมิให้สมรส หรือสามีภริยาต้องห้ามมิให้สัมผัสหรือเสพเมถุนแล้วแต่กรณี (มาตรา 145 ของคำแปลหลักกฎหมายอิสลาม)

⁴ มาตรา 51 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลของฟิลิปปินส์

ข) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการสมรสครั้งต่อมา (Subsequent marriage) เนื่องจากชายมุสลิมสามารถมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมกัน 4 คน¹ การที่ชายมุสลิมที่มีภรรยาอยู่แล้วมีความประสงค์จะทำการสมรสอีกครั้ง กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ ลำมี (มุสลิม) ผู้ใดที่มีความประสงค์จะทำการสมรสอีกครั้ง ก่อนที่จะทำการสมรสจะต้องเล่นหนังสืบบอกกล่าวกับ เลขาธิการศาลคำสนาประจำท้องถิ่นที่ตนเองมีครอบครัวอาศัยอยู่ เมื่อได้รับหนังสืบบอกกล่าวแล้ว เลขาธิการศาลจะต้องส่งสำเนาหนังสืบบอกกล่าวนั้นแก่ภรรยานั้นทุกคน ถ้าภรรยาคัดค้านจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย (Agama Arbitration council) ตามวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าคณะกรรมการไกล่เกลี่ยไม่ได้รับคำยินยอมจากภรรยาในการขอเล่นนอแต่งงานของลำมีนั้นแล้ว ภายใต้มาตรา 27² ไม่ว่ากรณีใดก็ตามศาลต้องอนุมัติตามคำคัดค้านของภรรยา³

เป็นที่น่าสังเกตว่า การมีภรรยามากกว่า 1 คน ที่กฎหมายอิสลามอนุญาตให้กระทำได้นั้น ฌาย์ข้อบังคับให้กระทำหรือขอใบให้กระทำ หากแต่เป็นเพียงข้ออนุมัติให้กระทำได้ และข้ออนุมัตินั้นจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ หากจะมีก็ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมที่ภรรยาเหล่านั้นจะได้รับ จุดมุ่งหมายของของความยุติธรรม คือความยุติธรรมระหว่างภรรยาในเรื่องการจ่ายค่าเลี้ยงดูและเรื่องอื่น ๆ ที่สามารถให้ความยุติธรรมได้⁴

¹ พระอัลลอฮ์ ได้ตรัสว่า "จงสมรสกับสตรีที่สุจริตใจ 2 คน 3 คนและ 4 คน ถ้าหากสุจริตใจเกรงว่ามิอาจจะให้ความยุติธรรมแก่นางเหล่านั้นได้ ก็จงสมรสแต่เพียงคนเดียว" มุณีร มุฮัมหมัด, กฎหมายอิสลาม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายสัมพันธ์, 2521) หน้า 101.

² มาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมฯ กำหนดว่าถึงแม้ว่ากฎหมายอิสลามอนุญาตให้มุสลิมมีภรรยาได้มากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 4 คนในเวลาเดียวกัน ชายมุสลิมก็มิอาจมีภรรยาจะมีภรรยาได้เกิน 1 คน เว้นแต่เขาได้ทำความตกลงกับภรรยาอย่างเสมอภาคและมิตรภาพ และจำต้องปฏิบัติตามข้อห้ามของกฎหมายอิสลาม

³ มาตรา 162 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

⁴ อับดุลกะรีม ไชดาน, ระบอบสังคมในอิสลาม, แปลโดยอิสมาอีล อาลี และมาลิก โยราลุมุท, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายสัมพันธ์, 2526) หน้า 44.

จะเห็นว่า แม้หลักคำสอนจะอนุมัติให้ชายมีภรรยาได้มากกว่า 1 คน แต่ก็ได้นั้นถึง ความสำคัญของภรรยาที่จะต้องได้รับความยุติธรรม เพื่อความเป็นเอกภาพของครอบครัว ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิม จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิด จากการที่สามีทำการสมรสอีก ถ้าหากภรรยาคัดค้านแล้วศาลต้องตัดสินตามคำคัดค้านของภรรยา เพื่อรักษาเอกภาพของครอบครัวเอาไว้ เพราะการที่ภรรยาคัดค้านแสดงว่าภรรยาจะต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมตามความมุ่งหมายของหลักคำสอนอิสลามดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ค) ไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีความผิดต่อกฎหมายประเพณี (Offeness against Customary) ในคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อกฎหมายประเพณี ศาลคำสอนอิสลาม ประจำท้องถิ่นเห็นว่าคดีนั้นอาจจะยุติลงได้โดยไม่ต้องทำการพิจารณาคดีตามรูปแบบ เป็นดุลพินิจ ของศาลที่จะสั่งให้เลิ้มียนศาลตั้งกรรมการที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คนและไม่เกิน 4 คน พร้อมกับ เลขานุการศาลในฐานะที่เป็นประธานกรรมการทำการปองดองในคดีนั้นด้วยไมตรีจิต¹

เนื่องจากลักษณะ เฉพาะสังคมในอิสลามที่ให้ความสำคัญต่อการเอาใจใส่ให้ความสำคัญ ต่อครอบครัว แนวทางในการจัดระบบครอบครัวอิสลามเป็นหัวใจของระบบอิสลาม² แต่อย่างไร ก็ตามก็ไม่ได้ล้มความจริงที่อาจจะเกิดขึ้น คือการขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาอันจะนำไปสู่การ หย่าร้าง ซึ่งแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือ การไกล่เกลี่ยปองดองกันระหว่างสามีภรรยา ฉะนั้น เมื่อรัฐได้ยอมรับให้เอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้กับมุสลิม จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากการหย่าร้าง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ก) การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเป็นการขจัดข้อขัดแย้งที่อาจจะลุกลามใหญ่โตออกไปโดยสามีภรรยา จะต้องแต่งตั้งผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาล่าเหตุของการขัดแย้งและหาทาง ปองดองกัน ซึ่งส่วนมากแล้วการไกล่เกลี่ยจะได้รับผลสำเร็จ ทั้งนี้ก็เพราะผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย

¹ มาตรา 163 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

² อับดุลกะรีม ไชดาน, ระบอบสังคมในอิสลาม, อ้างแล้ว, หน้า 44.

จะกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้การขัดแย้งยุติลงด้วยดี เสมอเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีความเกี่ยวพัน เป็นญาติกับฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ซึ่งสามารถรู้สาเหตุของการขัดแย้งเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ การแก้ไขปัญหายั่งยืน และพระอัลลอฮ์ได้ตรัสในเรื่องใกล้เคียงระหว่างสามีภรรยาไว้ว่า "และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะเกิดการแตกแยกระหว่างสามีภรรยา ก็จงส่งผู้แทนจากฝ่ายชาย และผู้แทนจากฝ่ายหญิง หากว่าทั้งสองต้องการปรองดองกัน อัลลอฮ์ก็จะประทานความสำเร็จ ให้แก่เจ้าทั้งสองนั้น"¹ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าการที่ให้มีคณะกรรมการใกล้เคียงข้อพิพาทระหว่าง สามีภรรยา จึงเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันครอบครัวมุสลิมอีกประการหนึ่ง

2. ที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Jurisconsult in Islamic Law) ประมวล กฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิม (Code of Muslim Personal Law of Philippines) ได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายอิสลามดังนี้คือ

ก) กางแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายอิสลามจะได้รับการ แต่งตั้งจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งคราวละ 7 ปี และไม่เป็นการ ตัดสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ เว้นแต่กรณีที่ถูกปลดออกเนื่องจากไม่สามารถจะปฏิบัติ หน้าที่ได้²

ข) คุณสมบัติของที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษากฎหมายอิสลามจะต้องมีคุณสมบัติคือ

- 1) เป็นพลเมืองของฟิลิปปินส์
- 2) มีอายุอย่างน้อย 40 ปี
- 3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความซื่อสัตย์และมีชื่อเสียงในฐานะ

ที่เป็นผู้รอบรู้ในคัมภีร์กุรอานและฮาดิซ และนิติศาสตร์อิสลาม ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในภาษา อาหรับ³

¹ อับดุลกะรีม ไชดาน, ระบอบสังคมในอิสลาม, อังแล้ว, หน้า 62.

² มาตรา 164 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 165 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

สถาบันที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายอิสลาม เพื่อขอความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งจะทำให้ปัญหายุติลงได้ก่อนที่จะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตออกไป และอีกประการหนึ่งก็เป็นการยุติปัญหาก่อนที่จะน่าคิดขึ้นสู่ศาล

ค. คณะกรรมการอิสลามของไทย ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการคำล้นูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พุทธศักราช 2488 กำหนดให้มีคณะกรรมการอิสลาม คือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและกรรมการมัสยิด ดังจะได้ศึกษารายละเอียดต่อไป

1. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐบาลอาจจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือแก่กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการในกิจการที่เกี่ยวข้องแก่ศาสนาอิสลาม¹ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งเป็นอิสลามศาสนิกมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 นาย แต่งตั้งและถอดถอนโดยพระบรมราชโองการตามคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จุฬาราชมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง²

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรี เพื่อให้คำปรึกษาแก่กรรมการศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการคำล้นูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม และให้มีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามสมควร³

2. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จังหวัดที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากพอสมควร กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือแก่ คณะกรรมการจังหวัดในกิจการที่เกี่ยวข้องแก่ศาสนาอิสลามในจังหวัดนั้น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งเป็นอิสลามศาสนิกมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 นาย แต่งตั้งและถอดถอนโดยกระทรวงมหาดไทย

¹ มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการคำล้นูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 .

² มาตรา 6 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการคำล้นูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 .

³ มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการคำล้นูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม (ฉบับที่ 2)

จังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทำหน้าที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้น ๆ¹

3. คณะกรรมการอิสลามประจำลุ่มแม่น้ำ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อาจจัดให้มีคณะกรรมการประจำลุ่มแม่น้ำ (มัสยิด) ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด โดยให้โต๊ะอิหม่ามเป็นประธาน² คณะกรรมการอิสลามประจำลุ่มแม่น้ำจะมีให้แห่งละไม่เกิน 15 คนประกอบด้วยอิหม่าม คอเต็บ อิหม่ามเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง อิหม่ามเป็นประธานกรรมการ คอเต็บเป็นรองประธานกรรมการ³ กรรมการอิสลามประจำลุ่มแม่น้ำที่ตั้งนี้คือ

ก) การจัดบำรุงรักษามัสยิดและศาสนาสัมปติ (วากัฟ) ตามพระธรรมนูญกฎหมาย ระเบียบและมติของที่ประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อยมั่นคงและเกิดผลประโยชน์

ข) แนะนำตักเตือนปวงสาธุชนให้ปฏิบัติศาสนกิจโดยเคร่งครัดและมีความสำนึก

ค) จัดทำเอกสารการบัญชีต่าง ๆ ของมัสยิดให้ถูกต้องและครบถ้วน

ง) จัดทำทะเบียนสาธุชน รักษาสมุดทะเบียนและจำหน่ายแก้ไขทะเบียนให้ถูกต้องอยู่เสมอ

จ) วางระเบียบปฏิบัติภายในมัสยิดเพื่อให้การบำเพ็ญศาสนกิจและพิธีกรรมเป็นไปโดยเรียบร้อย

ฉ) รับข้อพิพาทเรื่องศาสนาของปวงสาธุชน

ช) แจ้งการเห็นเดือนชะบาน รอมฎอน เชาวาล ชุลฮิจยะ ต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

¹ มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการคำสอนปณัฏ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488.

² มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการคำสอนปณัฏ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488.

³ ข้อ 4 ของระเบียบการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและวิธีดำเนินการอันเกี่ยวแก่ศาสนกิจของมัสยิด พ.ศ. 2492.



ข) จัดการ เรื่องครอบครัวและมรดกตามพระธรรมวินัย

ฅ) แสดงงบยอดบัญชีรับจ่ายและทะเบียนคำสนทนาคณะ กรรมการ

อิสลามประจำจังหวัดภายในเดือนมกราคมทุกปี

ญ) กรรมการแต่ละคนต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในกิจการทั่วไปของมัสยิด¹

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย จะเห็นว่าคณะกรรมการอิสลามมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการศาสนาอิสลาม คือกรรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกรมการจังหวัดเท่านั้น คณะกรรมการอิสลามไม่ได้มีบทบาทในการบริหารกฎหมายอิสลาม ดังเช่น คณะกรรมการอิสลามในสิงคโปร์และในฟิลิปปินส์ จะมีแต่คณะกรรมการมัสยิดที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาทเรื่องศาสนาของปวงสาธุชนและจัดการเรื่องครอบครัวมรดกตามพระธรรมวินัย เท่านั้นอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า

1. แม้คณะกรรมการอิสลามจะไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือให้คำปรึกษาในปัญหาข้อกฎหมายแก่คู่กรณีที่มีส่วนได้เสียดัง เช่น คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Agama Arbitration Council) ก็ตาม แต่ตามความเป็นจริงที่ปฏิบัติกันในสังคมอิสลามเมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนา ข้อขัดแย้งนั้นจะได้รับการไกล่เกลี่ยในระดับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก่อน² ซึ่งจะเห็นว่าคดีเกี่ยวกับครอบครัวมรดกอิสลามที่ยื่นมาสู่ศาลมีคดีตีความซึ่งก็เป็นผลมาจากการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั่นเอง

¹ ข้อ 6 ของระเบียบการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและวิธีการดำเนินการอันเกี่ยวแก่คำสนทนากิจมัสยิด พ.ศ. 2492.

² เรวัตรา ราชมุกดา ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้อภิปรายในการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามว่า ข้อพิพาทของมุสลิมได้สิ้นสุดลงที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ. 2524 จำนวน 201 เรื่องดูการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามฯ, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 105.

2. บทบาทของคณะกรรมการอิสลาม เริ่มได้รับการกล่าวถึงจากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในฐานะที่เป็นผู้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีอุทธรณ์ฎีกา และอาจร่วมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเพื่อทำการสอบความรู้อันจะสมัครเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นตะโต๊ะยุติธรรม

สำนักงานจดทะเบียนเกี่ยวกับการสมรส การหย่า

สำนักงานจดทะเบียนเกี่ยวกับการสมรส การหย่าของมุสลิมเป็นสถาบันทางศาสนาอิสลามอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารกฎหมายอิสลามในฐานะที่เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการสมรส การหย่าให้เป็นไปตามกฎหมายอิสลามให้เป็นไปโดยมีระเบียบเพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงสถานะทางครอบครัวของมุสลิม ฉะนั้น การจดทะเบียนสมรส การหย่าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ต่อไปนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส การหย่าตามกฎหมายอิสลามในประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก. สำนักงานจดทะเบียนเกี่ยวกับการสมรส การหย่าของมุสลิมในสิงคโปร์ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลาม ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสและการหย่าซึ่งสามารถนำมาบังคับใช้เกี่ยวกับการสมรสที่คู่กรณีฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายนับถือศาสนาอิสลามได้ประกอบพิธีสมรสตามกฎหมายอิสลาม¹

1. การแต่งตั้งนายทะเบียน ประธานาธิบดีสิงคโปร์อาจตั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นข้าราชการมุสลิม (ชาย) ที่มีความประพฤติดี มีความรู้และความเหมาะสมเป็นนายทะเบียนสมรสมุสลิม (Registra of Marriage) และประธานาธิบดีก็อาจยกเลิกการแต่งตั้งนั้นก็ได้²

¹ มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

² มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

2. การแต่งตั้ง Kathi และ Naib Kathi ประธานาธิบดีสิงคโปร์อาจแต่งตั้งชายมุสลิมที่มีความประพฤติดีและมีความรู้ความเหมาะสม เป็น Kathi หรือ Naib Kathi สำหรับท้องที่ใดท้องที่หนึ่งอาจแต่งตั้ง Kathi หรือ Naib Kathi 2 คน หรือมากกว่านั้นโดยระบุไว้ว่าเป็นการแต่งตั้ง Kathi หรือ Naib Kathi เป็นการเฉพาะท้องที่นั้น ๆ และสำหรับเฉพาะสำหรับสำนักกฎหมายหนึ่งสำนักกฎหมายใด Kathi¹ หรือ Naib Kathi ทุกคนถือว่าเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนสมัครมุสลิม²

3. หน้าที่ของ Kathi หรือ Naib Kathi เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดว่า ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ การสมัครจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อวาลี³ ของหญิงที่จะสมัครนั้นได้ประกอบพิธีสมัครตามกฎหมายอิสลาม⁴

ภายใต้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้ Kathi หรือ Naib Kathi ต้องขอให้วาลี ของหญิงที่จะทำการสมัครประกอบพิธีสมัคร แต่ก่อนที่จะทำการประกอบพิธีสมัคร Kathi หรือ Naib Kathi จะต้องทำการไต่สวนเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าการสมัครนั้นจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายอิสลาม หรือตามพระราชบัญญัตินี้ และจะไม่ทำการประกอบพิธีสมัครจนกว่าจะมีความแน่ใจ ส่วนในกรณีที่ไม่มีวาลีของหญิงที่จะทำการสมัคร หรือวาลีปฏิเสธที่จะประกอบพิธีแต่งงาน Kathi หรือ Naib Kathi จะเป็นผู้ประกอบพิธีสมัคร แต่ก่อนทำพิธีสมัคร Kathi หรือ Naib Kathi ต้องไต่สวนเพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครนั้นจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายอิสลามหรือตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้ นอกจากนั้น Kathi หรือ Naib Kathi อาจจะออกหมายเรียกบุคคล

¹ มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

² มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

³ วาลี คือชายผู้ทรงสิทธิประกอบพิธีสมัครให้หญิง หรือชายในกรณีที่ชายยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือวิกลจริต สิทธินี้เป็นเอกสิทธิ์ของวาลี บังคับวาลีไม่ได้ ในกรณีที่วาลีเป็นใบ้ วาลีต้องตั้งตัวแทน เพื่อประกอบพิธีสมัคร (มาตรา 29 ของคำแปลหลักกฎหมายอิสลาม)

⁴ มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์.

เพื่อเป็นพยานหรือแสดงหลักฐานก็ได้¹ นอกจากนั้นกฎหมายได้กำหนดถึงความสำเร็จของการ
สมรสเอาไว้ คือจะไม่มี การสมรสที่ประกอบพิธีตามประมวลกฎหมายฉบับนี้จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จของการสมรสตามกฎหมายอิสลามและบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติ²

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่า Kathi หรือ Naib Kathi นั้นมีหน้าที่
ทำการพิจารณาประกอบพิธีสมรสที่เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายอิสลาม และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ

เมื่อ Kathi หรือ Naib Kathi เห็นว่าการสมรสนั้นเป็นไปตามกฎหมายอิสลามและ
เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแล้ว Kathi หรือ Naib Kathi ต้องประกอบพิธีสมรส
และทำการจดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะกระทำการจดทะเบียนที่สำนักงานหรือที่บ้านของคู่กรณี

ในกรณีการแต่งงาน การหย่าหรือการเพิกถอนการหย่า (Revocation of
Divorce) ที่มีผลในเชิงปฏิบัติและยังไม่ได้จดทะเบียนสำนิกรรยาต้อง

ก) ไปด้วยตนเองที่สำนักงานของ Kathi ภายใน 7 วัน หลังจาก
ทำการสมรส การหย่าหรือเพิกถอนการหย่า

ข) จัดหารายละเอียดตามที่ Kathi ต้องการ เพื่อจะได้ทำการ
จดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าให้ถูกต้อง และ

ค) ทำคำขอตามแบบพิมพ์ที่ได้กำหนดไว้สำหรับจดทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า หรือเพิกถอนการหย่าแล้วแต่กรณี

Kathi จะไม่จดทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่า จนกว่าจะแน่ใจว่าทั้งสองฝ่าย
มีความยินยอมให้หย่าหลังจากที่ได้ทำการไต่สวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว

1
มาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

2
มาตรา 90(1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

Kathi จะไม่จดทะเบียนหย่าโดย 3 ตอละ

ในกรณีขอให้ Kathi จดทะเบียนหย่าโดย 3 ตอละ หรือในกรณีการขอให้จดทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่า ซึ่ง Kathi ไม่แน่ใจว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะให้ความยินยอมในการจดทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่านั้น Kathi จะต้องส่งคำร้องขอขึ้นไปยังศาลคำสอนอิสลาม (Sharia Court) ให้เป็นผู้ออกคำสั่งหรือชี้ขาด

บทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนไม่ลามาธนาห์มาใช้กับกรณีการหย่าเป็นผลมาจากคำสั่งหรือคำชี้ขาดของศาลคำสอนอิสลาม หรือคณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Board)¹

ในกรณีที่ประกอบพิธีสมรส Kathi หรือ Naib Kathi จะต้องจดทะเบียนสมรสโดยลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสลงในทะเบียนสมรส และลงในใบรับรองการสมรสแล้วรวมไว้กับทะเบียน การจดทะเบียนนั้นต้องลงลายมือชื่อ Kathi หรือ Naib Kathi และคู่กรณีและพยานตามจำนวนที่ได้กำหนดเอาไว้ก่อนจะทำการจดทะเบียน Kathi หรือ Naib Kathi ต้องทำการไต่สวนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการสมรส การหย่าหรือเพิกถอนการหย่านั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และอาจออกหมายเรียกให้บุคคลมาเป็นพยานหรือส่งมอบเอกสาร² ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่า Kathi หรือ Naib Kathi ต้องส่งสำเนาใบรับรองการจดทะเบียนดังกล่าวแล้วแต่กรณีไปยังนายทะเบียน³

4. การยกเลิกหรือแก้ไขการจดทะเบียนหรือใบรับรองการจดทะเบียน ถ้าหากปรากฏว่ารายการที่ลงไว้ในทะเบียนหรือในใบรับรองการจดทะเบียนที่ได้ออกตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อผิดพลาด หรือมีรายละเอียดผิดพลาดซึ่งจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง นายทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดนั้น สามารถยื่นคำขอต่อศาลคำสอนอิสลามเพื่อทำการยกเลิกหรือแก้ไขในรายการใบรับรองการจดทะเบียน ศาลคำสอนอิสลามหลังจากที่ทำการไต่สวนแล้วอาจมีคำสั่งยกเลิกหรือแก้ไขตามที่ขอ⁴

¹ มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

² มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์

³ มาตรา 93 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์.

⁴ มาตรา 95 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์



5. การปฏิเสธการจดทะเบียน (Refusal to Register) ในกรณีที่ Kathi หรือ Naib Kathi เห็นว่าการจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าไม่เป็นไปตามกฎหมายอิสลามหรือตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสิ่งต้องปฏิเสธการจดทะเบียนโดย Kathi หรือ Naib Kathi ต้องปฏิบัติดังนี้คือ ต้องบันทึกเหตุผลที่ปฏิเสธการจดทะเบียนการล้มรลทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าลงในสมุดทะเบียนพร้อมทั้งแจ้งการปฏิเสธนั้นไปยังนายทะเบียนและ Kathi หรือ Naib Kathi อื่น ๆ ทั้งหมดในลิงคโปร และ Kathi หรือ Naib Kathi ต้องทำสำเนาเหตุผลที่ปฏิเสธการจดทะเบียนนั้นให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเมื่อได้รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว¹

6. การอุทธรณ์การปฏิเสธการจดทะเบียน เมื่อ Kathi หรือ Naib Kathi ได้ปฏิเสธการจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่า ผู้ที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวก็สามารถอุทธรณ์คำปฏิเสธนั้นไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Board) โดยอนุโลมตามบทบัญญัติในกรณีที่อุทธรณ์คำตัดสินของศาลคำสำนามายังคณะกรรมการอุทธรณ์²

7. การมอบทะเบียนให้แก่คู่กรณี เมื่อทำการจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าเรียบร้อยแล้ว Kathi หรือ Naib Kathi ต้องมอบสำเนาใบรับรองการจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าแล้วแต่กรณีแก่คู่กรณีในเวลาอันสมควรโดยต้องประทับตราประจำของสำนักงาน³

8. ผลทางกฎหมายในการจดทะเบียน (Legal Effect of Registration) การจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่าของมุสลิมไม่ใช่แบบแห่งการล้มรลที่จะทำให้การล้มรล การหย่ามีความสมบูรณ์ การล้มรลจะสมบูรณ์หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจดทะเบียน แต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าการล้มรล การหย่านั้นได้กระทำถูกต้องตามหลักคำสอนอิสลามหรือไม่ ฉะนั้น การจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่าจึงไม่ใช่สิ่งที่จะกล่าวอ้างถึงการล้มรล การหย่าของมุสลิมว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์⁴

¹ มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของลิงคโปร.

² มาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของลิงคโปร.

³ มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของลิงคโปร

⁴ มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของลิงคโปร

ข. สำนักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าและการเปลี่ยนแปลงคำสอนของ
ฟิลิปปินส์ ประมวลกฎหมายว่าด้วยสถานบุคคลมุสลิม (Code of Muslim Personal Laws
 of Philippines) ได้กำหนดให้มีสำนักงานเพื่อทำหน้าที่จดทะเบียนต่าง ๆ ตามกฎหมายอิสลาม
 คือ

1. สำนักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าและการ
เปลี่ยนแปลงคำสอนอิสลามประจำภาค (Distric Registrar of Muslim Marriage,
divorc Revocation of Divorce and Conversion) เลขานุการประจำศาลคำสอน
 อิสลามประจำภาค นอกจากจะมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้แล้ว ต้องทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมรส
 ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าและการเปลี่ยนแปลงคำสอนภายในเขตศาลนั้น ๆ (Territorial
 Jurisdiction)¹

หน้าที่ของนายทะเบียนประจำภาค (Distric Registrar) คือ

1. นายทะเบียนประจำภาคทุก ๆ คนที่มีหน้าที่ตรวจตราดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
 นายทะเบียนประจำท้องถิ่น
2. ลงรายการบัญชีเอกสาร เก็บและรักษาลำเนาใบรับรองการจดทะเบียนสมรส
 ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่า และการเปลี่ยนแปลงคำสอนที่นายทะเบียนประจำท้องถิ่นส่งมา
3. ต้องส่งสำเนาทะเบียนดังกล่าวไปยังสำนักงานทะเบียนทางแพ่ง-กลาง (Civil
 Registrar-General)²

2. สำนักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าและการ
เปลี่ยนแปลงคำสอนประจำท้องถิ่น (Circuit Registrar of Muslim Marriage,
Divorce, Revocation of Divorce and Conversion) เลขานุการศาลคำสอนอิสลาม
 ประจำท้องถิ่น (Sharia Circuit Court) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

¹
 มาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์.

²
 มาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์.

หรือเพิกถอนการหย่าและการเปลี่ยนแปลงคำสัญญาประจำศาลคำสัญญาอิสลามประจำท้องถิ่น¹
หน้าที่ของนายทะเบียนดังกล่าวคือ

1. เก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบเกี่ยวกับใบรับรองการจดทะเบียนต่าง ๆ
ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่ส่งมาให้นายทะเบียน
2. รวบรวมหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นรายเดือน เตรียมเอกสาร
ต่าง ๆ ส่งให้นายทะเบียนประจำศาลคำสัญญาอิสลามประจำภาคตามที่ต้องการ
3. จดทะเบียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำสัญญาอิสลาม
4. รับรองการคัดสำเนาหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ
หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน
5. ส่งสำเนารายการจดทะเบียนที่ได้กระทำในระหว่างเดือนก่อนให้แก่นายทะเบียน
ประจำศาลคำสัญญาอิสลามประจำภาค ภายใน 10 วันแรกของเดือนถัดไปทุก ๆ เดือน
6. จัดทำสารบรรณเอกสารต่าง ๆ เพื่อส่งต่อการอ้างอิงหรือส่งต่อการ
นำมาเป็นหลักฐานเมื่อต้องการ²

3. การยกเลิกหรือแก้ไขรายการจดทะเบียน (Cancellation or Correction of Entry) ในกรณีที่การจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคำร้องต่อศาลคำสัญญาอิสลามประจำภาคเพื่อขอให้ศาลแก้ไขให้ถูกต้องภายใต้บทบัญญัติของระเบียบศาล (Rule of Court) นอกจากนั้น นายทะเบียนทุกคนต้องรับผิดชอบทางแพ่ง -- เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายการจดทะเบียนโดยไม่มีอำนาจต่อผู้เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงและการจดทะเบียนนั้น แต่อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนอาจจะพ้นจากการรับผิด ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นมีเหตุผลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความไม่ชอบด้วยกฎหมายล่วงหน้า³

¹ มาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลของฟิลิปปินส์

² มาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลของฟิลิปปินส์.

4. ผลทางกฎหมายของการจดทะเบียน หนังสือที่ออกโดยสำนักงานจดทะเบียน ส้มรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าและการเปลี่ยนแปลงคำสัญญา และเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการจดทะเบียนดังกล่าว ถือว่าเป็นเอกสารมหาชนและถือว่าเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นสำหรับ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนนั้น อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดตามบทบัญญัตินี้จะ เป็นผลทำให้เกิดความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยผลจากการจดทะเบียน¹

5. การใช้กฎหมายอื่นเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางแพ่ง ในกรณีที่กฎหมายอื่น เกี่ยวกับการจดทะเบียนทางแพ่ง จะนำมาใช้ได้ก็แต่เฉพาะที่ไม่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติตาม ประมวลกฎหมายนี้ เมื่อบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนอื่น ๆ ที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติ ของประมวลกฎหมายนี้ นายทะเบียนประจำภาคหรือประจำท้องถิ่นต้องถือตามสำนักงานจดทะเบียน ทางแพ่งอื่น ๆ²

จากการที่ได้ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานการจดทะเบียน เกี่ยวกับการส้มรส การ หย่าในประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ จะเห็นว่าบทบาทของสำนักงานจดทะเบียนดังกล่าว มีความ จำเป็นมากสำหรับการบริหารกฎหมายอิสลาม เพราะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายอิสลามโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคำสัญญาอิสลาม และออกหนังสือ รับรองการจดทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างสิทธิอัน เกิดจากสถานะทางครอบครัว

ค. สำนักงานจดทะเบียนส้มรส ทะเบียนหย่าของไทย สำหรับประเทศไทย
ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีสำนักงานจดทะเบียนส้มรส ทะเบียนหย่าตามกฎหมายอิสลาม ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทย ได้นำเข้ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ในชุมชนมุสลิมมานานแล้ว จะมีก็แต่สำนักงานจดทะเบียนตาม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดแบบ แห่งการส้มรสเอาไว้ คือต้องทำการจดทะเบียน³ และมีพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 มาตรา 40 ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอเป็นนายทะเบียน ซึ่งอาจจะจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหรือนอกสำนักงานทะเบียนก็ได้

¹ มาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายสถานการณ์บุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

² มาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายสถานการณ์บุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์

³ มาตรา 1457 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การส้มรสตามประมวลกฎหมาย

นี้มีได้เฉพาะเมื่อจดทะเบียนแล้ว เท่านั้น

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่าตามกฎหมายอิสลามมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารกฎหมายอิสลาม ซึ่งในการจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่านี้แม้แต่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมก็จัดให้มีสำนักงานทะเบียนเพื่อจดทะเบียนต่าง ๆ ตามกฎหมายอิสลาม¹ โดยจะทำให้การบริหารกฎหมายอิสลามเป็นไปโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ การจดทะเบียนนั้นเป็นการแสดงในเบื้องต้นว่า การล้มรล การหย่านั้นได้กระทำถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม และสามารถนำเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนั้นมา เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิอันเกิดจากฐานะทางครอบครัวได้ เช่นเดียวกับการจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่ง ถ้าไม่มีหลักฐานทางคำสอนอิสลามที่เจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการล้มรลหรือการหย่าแล้ว สิ่งเป็นการยากที่จะพิสูจน์และทราบว่าการล้มรลหรือการหย่านั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้กฎหมายอิสลามเอาไว้กว้าง ๆ ไม่ได้กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนล้มรล ทะเบียนหย่า ซึ่งเป็นผลทำให้การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยจำกัดอยู่แต่เฉพาะในศาลเท่านั้น กฎหมายอิสลามไม่สามารถจะนำมาบังคับใช้นอกศาลได้ เพราะมีแต่ศาลชั้นต้นโดยเฉพาะตะต๊ะยุติธรรมเท่านั้นที่เป็นสถาบันเดียวที่เป็นสถาบันเดียวที่มีหน้าที่ในการบริหารกฎหมายอิสลาม ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ตะต๊ะยุติธรรมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชี้ว่า การล้มรลหรือการหย่าเป็นไปตามกฎหมายอิสลาม และมีผลตามกฎหมายอิสลาม เมื่อมีคำชี้ขาดของตะต๊ะยุติธรรมแล้วจึงสามารถนำเอาคำชี้ขาดนั้นยืนยันสิทธิอันเกิดจากสถาบันทางครอบครัวได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการอื่น จึงผูกพันตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลในเรื่องดังกล่าว² ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากในทางปฏิบัติ

¹ มาตรา 116(1) แห่ง Enactment No. 3 of 1959, State of Penang การล้มรลจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อได้ประกอบพิธีล้มรลตามกฎหมายอิสลามโดยนายทะเบียนแห่งสถานที่ทำการล้มรลและประกอบพิธี และมาตรา 2 ของกฎหมายว่าด้วยการล้มรลของอินโดนีเซียกำหนดว่า การล้มรลนั้นสมบูรณ์ทุกอย่างตามกฎหมายกำหนดไว้ การล้มรลทุกอันไม่ว่าจะล้มรลตามลัทธิคำสอนใดก็ตาม ก็ต้องจดทะเบียน

² สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม 2 เมษายน 2526, ตอน 1, หน้า 132.

เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการอื่นไม่อาจจะทราบได้ว่าการล่มสหรือการหย่าตามกฎหมายอิสลามแล้ว เพราะการล่มส การหย่าตามกฎหมายอิสลามนั้นมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการล่มส และต้องประกอบพิธีซึ่งแตกต่างไปจากการล่มส การหย่าตามกฎหมายแพ่ง และผลของการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการล่มสตามกฎหมายอิสลามนั้นก็คือ เป็นโมฆะทันที¹ ฉะนั้น ในทางปฏิบัติของรัฐในส่วนราชการอื่นจึงไม่อาจจะรับรองผลของการล่มส การหย่าได้ด้วยตนเอง สิ่งจำเป็นที่จะต้องให้มีสถาบันทางศาสนาอิสลามรับรองหรือชี้ขาดมาเสียก่อนสถาบันทางศาสนาอิสลามมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้รับรองหรือชี้ขาดผลของการล่มสหรือการหย่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ในขณะนี้ คือศาลชั้นต้นโดยตะต๊ะยุติธรรมซึ่งแตกต่างจากกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่มี Kathi หรือ Naib Kathi เป็นผู้ทำการจดทะเบียนล่มส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่า ที่เห็นว่าการล่มสหรือการหย่านั้นได้กระทำถูกต้องตามกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลาม ส่วนในกรณีที่ Kathi หรือ Naib Kathi เห็นว่าการจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายอิสลาม ก็อาจปฏิเสธคำขอจดทะเบียนได้ แต่คู่กรณีก็อาจอุทธรณ์คำปฏิเสธนั้นไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Board) จะเห็นว่าในชั้นแรก Kathi หรือ Naib Kathi ในฐานะรองนายทะเบียนจะเป็นผู้รับรองการจดทะเบียนตามกฎหมายอิสลาม โดยการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่เห็นว่าเป็นปัญหาเท่านั้น สิ่งให้ศาลศาสนาอิสลามเป็นผู้ชี้ขาด เช่นการหย่าโดย 3 ตอละ ต้องให้ศาลศาสนาอิสลามเป็นผู้ชี้ขาดหรือในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนก็กระทำได้ด้วยศาลศาสนาอิสลามเป็นผู้สั่ง

ฉะนั้น สิ่งควรจะให้ให้มีการจดทะเบียนล่มส ทะเบียนหย่าตามกฎหมายอิสลาม อย่าลืมว่าการจดทะเบียนตามกฎหมายอิสลามนั้นไม่ได้เป็นแบบแห่งการล่มสที่ทำให้การล่มสหรือการหย่าไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ได้จดทะเบียนดังเช่นตามกฎหมายแพ่ง การล่มสหรือการหย่านั้นย่อมสมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลามทุกประการตราบเท่าที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดการล่มสตามกฎหมายอิสลามแต่ที่จดทะเบียนก็เพื่อจะให้ทางราชการได้รับรองการล่มส การหย่าซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักฐาน

¹ มาตรา 23 ของคำแปลหลักกฎหมายอิสลาม การล่มสจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ประกอบพิธีถูกต้องภายในบังคับบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้.

อ้างสิทธิอันเกิดจากสถานะภาพทางครอบครัวได้โดยไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลชี้ขาด สำหรับการสมรส การหย่าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ แต่ก็ไม้อาจจะนำไปอ้างอิง เพื่อก่อให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ขึ้นมาได้ เพราะขาดหลักฐาน นอกจากจะมีคำสั่งหรือคำชี้ขาดของศาลแล้ว แม้จะไม่ได้จดทะเบียนก็สามารถนำไปอ้างสิทธิต่าง ๆ ได้¹ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนราชการอื่นต้องผูกพันตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาล หรือในกรณีที่เป็นการพิจารณาคดีในศาล แม้จะไม่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียน คู่กรณีก็อาจจะอ้างถึงความสมบูรณ์ของการสมรส การหย่าตามกฎหมายอิสลามได้โดยไม่ต้องนำเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส การหย่ามาอ้างต่อศาล

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าตามกฎหมายอิสลาม ในทางนิติบัญญัติก็ตาม แต่ในทางพฤตินัยแล้วมีการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าอยู่แล้วในหมู่สังคมมุสลิม เพียงแต่ไม่ได้รับการรับรองจากทางราชการเท่านั้น โดยโต๊ะอิหม่ามหรือคอเต็บเป็นผู้ดำเนินการ คือเมื่อโต๊ะอิหม่ามหรือคอเต็บทำการสมรสหรือการหย่า โต๊ะอิหม่ามจะออกหนังสือรับรองการสมรสหรือหนังสือรับรองการหย่าเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตัว² แต่หลักฐาน

¹ กรณีเช่นเดียวกับ มาตรา 96 (6) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์ กำหนดว่า บทบัญญัติทั้งหลายเกี่ยวกับการจดทะเบียนไม้อาจจะนำมาใช้ได้กับกรณีผลของการหย่าโดยคำสั่งของศาลนาอิสลาม หรือของคณะกรรมการอุทธรณ์

² ระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิกะห การตอละและการรอเอยะของคณะกรรมการกลางอิสลามในประเทศไทย

ข้อ 1. ต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนและใบสำคัญพินิจะห พินิตอละและวิธีรอเอยะ เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตัวของผู้เป็นสามีภรรยา หรือการขาดจากการเป็นสามีภรรยา กันต่อบุคคลภายนอกหรือต่อทางการแล้วแต่กรณี ให้มีลียิตหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการในกิจการนิกะห การตอละ และการรอเอยะถือปฏิบัติเป็นระเบียบเดียวกันทั่วราชอาณาจักร (เว้นแต่ในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการอยู่แล้ว)

ข้อ 2. ให้โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้มีหน้าที่ในกิจการนิกะห การตอละและการรอเอยะให้แก่สัปบุรุษในเขตมัสยิดนั้น หรือบุคคลในท้องถิ่นอันไม่ขัดกันกับระเบียบนี้ อนึ่ง ถ้าอิหม่ามไม่สามารถปฏิบัติกิจการตามระเบียบนี้ ก็ให้คณะกรรมการมัสยิดแต่งตั้งบุคคลใดที่เห็นสมควร

การจดทะเบียนที่ออกโดยโต๊ะอิหม่ามไม้อาจจะนำมาอ้างสิทธิอันเกิดจากสถานทางครอบครัวได้ เช่น ไม้อาจจะนำมาเป็นหลักฐานว่าเป็นภรรยาของผู้ตายเพื่อรับมรดก เป็นต้น ลำเหตุที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลอื่น ๆ ไม้อาจรับรองผลของการจดทะเบียนของโต๊ะอิหม่ามก็เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 มาตรา 40 กำหนดให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอเท่านั้นเป็นนายทะเบียน ไม่ได้กำหนดให้โต๊ะอิหม่ามหรือคอเต็บเป็นนายทะเบียน ซึ่งแตกต่างจาก Kathi หรือ Naib Kathi ตามพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์ที่กำหนดให้ Kathi หรือ Naib Kathi เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน เจ้าหน้าที่ของฝ่ายอื่น ๆ จึงไม้อาจรับรองการจดทะเบียนของโต๊ะอิหม่ามได้ เพราะไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดความรับผิดชอบของโต๊ะอิหม่ามเอาไว้เหมือนกับกรณีของนายทะเบียนประจำศาลาอิสลามของฟิลิปปินส์ที่กฎหมายกำหนดให้นายทะเบียนต้องรับผิดชอบแพ่งต่อผู้เสียหาย ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนโดยไม่มีอำนาจ

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นจุดบกพร่องที่น่าจะได้รับการแก้ไขอีกประการหนึ่งสำหรับการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย เพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้การบริหารกฎหมายอิสลามประสบปัญหาซึ่งจะเป็นผลให้การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยไม่อาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อจะให้อิสลามคำสนิกประกอบศาสนกิจได้ตามศรัทธาสัมกับที่เป็นประชาชนชาวไทย อันเป็นประเทศเอกราชได้

ง. สรุปโครงสร้างการองค์กร (Structural Organization) และเจ้าหน้าที่ทางศาสนา (Religious official) โครงสร้างของการองค์กรสำหรับการบริหารกฎหมายอิสลามนั้นมีความสำคัญมาก มีคนกล่าวว่าท่าทีของทางราชการต่อการบริหารกฎหมายอิสลามนั้น

ขึ้นท่าการแทนได้

เจ้าหน้าที่ในกิจการนี้ให้ถือว่าเป็นตำแหน่ง "น้าเอิบ" ประจำเขตกอร์ยะหัมลีอิสลามหนึ่ง ๆ

ข้อ 3. การทำพิธีนิกะห์ ตอละและรอเยาะให้เป็นหน้าที่ของน้าเอิบที่ได้รับสมุททะเบียนใบสำคัญนิกะห์ ใบสำคัญการตอละและใบสำคัญการรอเยาะจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วเท่านั้น (ตามแบบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ใช้แล้วทำระยะ เบียบนี้)

สังเกตได้จากองค์กรที่ทางราชการได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อบริหารกฎหมายอิสลาม ความสำคัญของโครงสร้างการปกครองมีความสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดสาระของกฎหมายอิสลามที่จะนำมาบังคับใช้¹

สำหรับโครงสร้างการปกครองเพื่อบริหารกฎหมายอิสลามในประเทศต่าง ๆ มีดังนี้

1. ประเทศสิงคโปร์ตามพระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของสิงคโปร์ ได้จัดระเบียบของศาลศาสนาอิสลามดังนี้

- ก) คณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Board)
- ข) ศาลศาสนาอิสลาม (Sharia Court)
- ค) Chief Kathi
- ง) Kathi Basar
- จ) Naib Kathi

2. ประเทศฟิลิปปินส์ตามประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิม ได้แบ่งศาลศาสนาอิสลามออกเป็น 3 ระดับคือ

- ก) ศาลศาสนาอิสลามประจำภาค (Sharia Distric Court)
- ข) ศาลศาสนาอิสลามประจำท้องถิ่น (Sharia Circuit Court)
- ค) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Agama Arbritration council)

สำหรับกรณีที่เราเป็นจะต้องมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

3. ประเทศศรีลังกาได้ก่อตั้งศาลศาสนาอิสลามขึ้น ดังนี้

- ก) คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board)
- ข) Quazi Court มีจำนวน 239 ศาล
- ค) Speccial Quazi Court มีจำนวน 52 ศาล

1

Datu Michael O. Mastura, Administration of Muslim Personal Laws System in a Muslim-Minority Country, Manila Philippines, p. 17.

สำหรับเจ้าหน้าที่ทางศาสนาอิสลามตามบทบัญญัติ เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามใน
ปัจจุบันได้ยอมรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาอิสลามดังนี้

1. Quazi หรือ Kathi เป็นเจ้าหน้าที่สำหรับประกอบพิธีและจดทะเบียนสมรส
ในประเทศสิงคโปร์และประเทศศรีลังกา
2. เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างลัทธิภรรยา
ในประเทศสิงคโปร์ ศรีลังกาและฟิลิปปินส์¹

สำหรับประเทศไทยที่มีมติคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามที่ฟ้อง
ร้องยังศาลในเขต 4 จังหวัดภาคใต้ โดยทำการพิจารณาคดีในนามของศาลจังหวัดที่อยู่ในเขต
4 จังหวัดภาคใต้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ Datu Michael O. Mastura, Administration of Muslim Personal
Laws System in a Muslim-Minority Country, p. 15.